26税务师《涉税服务相关法律》三色笔记

黄色：易错易混　　红色：理解攻坚　　蓝色：记忆巩固

第一章 行政法基本论

【考点1】行政法的基本原则(★★)

一、行政合法性原则（形式合法性原则）

1.行政权力的存在有法律依据；

2.行政权力必须按照法定程序行使。

【例】税务机关征税既要符合实体法（如，所得税法）的规定，又要符合程序法（如 税收征管法）的规定。

【注】行政合法性原则讲的是无法律无行政的问题，即“法无授权即禁止”。公民权叫“法无禁止即自由”。

二、行政合理性原则（实质合法：行政裁量权的体现）

1.行政行为应符合立法宗旨及意图，目的。

【例】城管不能追着“小贩”满街跑。

2.行政行为应建立在考虑相关因素的基础上。

3.平等地适用法律规范，遵循行政惯例或先例，做到相同情况相同对待，不同情况区别对待。

4.行政行为应保持适度、符合比例原则要求。

【例】政府不能用“大炮”打“蚊子”。

5.行政行为应符合法理、情理及事理要求，符合自然规律、客观性要求和社会道德观念，符合人类理性和公平正义观念。

三、行政应急性原则（合法性例外），行使条件

1.存在明确无误的紧急危险或者危害；

2.非法定机关不得行使应急权力，否则无效，事后追认除外；

3.行政机关作出应急行为应接受有权（权力）机关的监督；

4.行政机关行使应急权力时，应当尊重和保障人权，应当遵循合目的原则、比例原则以及安全原则。

【注】遵循比例原则主要是要求行政应急行为应当适当、适度，尽最大可能将负面损害控制在最小或者最低程度的范围内。

【考点2】行政法的渊源(★★)

一、行政法渊源

行政法的渊源，是指行政法律规范的外部表现形式和来源。

1. 宪法
2. 法律（效力仅次于宪法）
3. 法规（包括：行政法规、地方性法规）
4. 规章（包括：部门规章、地方政府规章）
5. 民族自治条例和单行条例（双备案）
6. 其他渊源

二、授权立法模式

1. 针对全国人大及其常委会专属立法权范围内的事项尚未制定法律的，可授权国务院根据实际需要，对其全部或部分事项先行制定行政法规，但是有关犯罪和刑罚、 对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。
2. 授权的期限不得超过 5 年，但是授权决定另有规定的除外。
3. 被授权机关应当在授权期限届满的 6 个月以前，向授权机关报告授权决定实施 的情况

三、行政法渊源中效力冲突的解决方式

法律渊源效力冲突	解决方式
法律新的一般规定 vs 法律旧的特殊规定	全国人大常委会裁决
行政法规新的一般规定 vs 行政法规旧的特殊规定	国务院裁决
法律制定机关授权制定的法规 vs 法律	全国人大常委会裁决
地方性法规 vs 部门规章	国务院提出意见： 1. 地方性法规直接适用 2. 部门规章→全国人大常委会裁决
部门规章 vs 部门规章	国务院裁决
部门规章 vs 地方政府规章	国务院裁决

【考点3】行政主体的特征及行政职权（★★）

一、行政主体的特征

行政主体，是指依法享有行政权力，能以自己的名义行使行政权，作出影响行政 相对人权利义务的行政行为，并能独立承担由此产生的相应法律责任的组织。国家行 政机关是最主要的行政主体。经法律、法规授权行使一定行政职权的特定社会组织， 也是行政主体。

1. 行政主体是组织。但并非所有的组织都是行政主体。
2. 行政主体是享有行政权力的组织。
3. 行政主体是能以自己的名义行使行政权的组织。
4. 行政主体是能够独立承担法律责任的组织。

二、行政主体的行政职权

（一）行政职权的概念及特征

概念	行政职权是行政主体实施国家行政管理活动的资格及权能。有权力的一般 属性，如强制性、命令性、执行性等
特征	1. 公益性：行政职权的设定与行使不是以行政主体自身的利益为目的，而 是以国家和社会的公共利益为目的 2. 优益性：行政主体行使行政职权时依法享有的优先权和受益权，合称为 行政优益权 3. 支配性：行政职权一经行使，在没有被国家有权机关撤销之前，相对人 是必须遵守执行 4. 不可自由处分性：不得随意转移、不得随意放弃或抛弃

【考点4】行政机关及其工作人员（★★）

行政机关，是指依宪法或者行政组织法的规定，而设置的行使国家行政职能的国家机关。

一、中央行政机关与地方行政机关

行政机关	是否是行政主体

中央行政机关	国务院	√
	国务院组成部门（“× 部、× 委员会”、中国人民银行、审计署，简称“部、委、行、署”）	√
	国务院直属特设机构（国资委）	√
	国务院直属机构（“× 总局”、“× 总署”“x 局”“中国证监监督管理委员会”“国家金融监督管理总局”等）	√
	国务院直属事业单位（“x 社、x 院、x 台、x 中心等”）	一般不是行政主体，经过授权后具有行政主体资格，经授权的有权制定部门规章
	国务院部委管理的国家局（“× 局”）	√
	国务院办事机构（“x 室”）	×
地方行政机关	地方各级人民政府及其职能部门、地方各级 人民政府的派出机关	√

【考点5】行政行为的分类(★★)

分类标准	内容
以适用与效力作用的对象范围为标准	内部行政行为，对内，如针对公务员的行政处分
	外部行政行为，对外，如行政强制、行政征收等
以对象是否特定为标准	抽象行政行为，即制定规范性文件，对象不特定不具体
	具体行政行为，对象特定具体，如行政处罚、行政许可等
以受法律规范拘束的程度为标准	羁束行政行为，如税务局征税
	裁量行政行为，如税务局罚款
以行政主体是否可以主动作出行政行为为标准	依职权的行政行为，如行政征收、行政处罚、行政强制、税务 局征税
	依申请的行政行为，如行政许可、行政复议
以行政行为成立时	单方行政行为，如行政处罚、行政许可等

参与意思表示的当事人数目为标准	双方行政行为，如行政协议，代表为投资协议	
以行政行为是否应当具备一定的法定形式为标准	要式行政行为，绝大多数行政行为 【注】指法律、法规明确规定必须具备特定形式才能成立	
	非要式行政行为 【注】指法律未强制要求特定形式的行为	
以行政行为是否以作为方式表现为标准	作为行政行为，如行政处罚、行政许可、行政奖励、行政强制 行为等	
	不作为行政行为，如公安局不履行保护人身权、财产权的法定职责	
以行政行为的内容对行政相对人是否有利为标准	授益性行政行为，如行政许可、行政奖励、行政给付、税务局 确认或决定减税免税	
	损益性行政行为，如行政处罚、行政征收等	
以行政权作用的表现方式和实施行政行为所形成的法律关系为标准	行政立法行为，如制定行政法规和行政规章	
	行政执法行为，如行政许可、行政确认、行政奖励、行政处罚、 行政强制、行政监督检查等	
	行政司法行为（“准”司法），如行政调解、行政裁决、行政仲裁、 行政复议等 【注】行政诉讼不属于行政司法，而是真正的司法行为	
行政终局裁决行为	“法律”规定由行政机关最终裁决的行政行为	均不可打行政诉讼
国家行为	涉及国家重大利益，具有高度政治性的行为，如国防、 外交，如果行政相对人因此遭受损失，可申请国家补偿	

第二章 行政许可法律制度

【考点1】行政许可设定权划分（★★）

法律渊源	设定权限
法律 —经常性许可	是确定行政许可的主要依据，以下只能由法律予以设定： 1. 国家基本制度，如采矿许可、草原使用许可、伐木许可等

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 公民基本权利，如公民健康权、环境权、劳动权的许可制度</td></tr>
<tr><td>行政法规
—经常性许可</td><td colspan="2">尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可
【注】 必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定临时性行政许可，如有关网约车的许可来自于 2004 年国务院的决定，但此 决定属于规章以下的规范性文件，不是行政法规</td></tr>
<tr><td>地方性法规
—经常性许可</td><td>尚未制定法律、行政法规的，地方性 法规 可以 设定行政许可</td><td rowspan="2">1. 不得设定应当由国家统一确定的公民、法人 或其他组织的资格、资质的许可
2. 不得设定企业或其他组织的设立登记及其前 置性许可（如取得《食品卫生许可证》后才能 办理《营业执照》）
3. 其设定的行政许可，不得限制其他地区的个 人或者企业到本地区从事生产经营和提供服 务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场</td></tr>
<tr><td>省级地方政府规章
—临时性许可</td><td>省、自治区、直辖市 政府规章 可以 设定临时性的行政许可</td></tr>
<tr><td>其他规范性文件</td><td colspan="2">包括部门规章，不得设定行政许可</td></tr>
</table>

【考点2】行政许可的撤回、撤销和注销(★★)

一、行政许可的变更撤回

可变更撤回	行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行 政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要， 行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可
有损失应补偿	由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当 依法给予补偿

二、行政许可的撤销

可以撤销 规律：一般贬义词 （官员错）	1. 工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定 2. 超越法定职权作出准予行政许可决定的 3. 违反法定程序作出准予行政许可决定的 4. 对不具备申请资格或不符合法定条件的申请人准予行政 许可的 5. 依法可以撤销行政许可的其他情形
应当撤销 规律：骗贿（百姓错）	相对人以欺骗或贿赂等不正当手段取得行政许可
【注】撤销可能对公共利益造成重大损失时，不得撤销	

三、行政许可的注销规律：客观原因

到期了	行政许可有效期届满未延续的
人死丧	赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的； 如律师死亡，其资质子女不能继承，只能注销
组织死	法人或者其他组织依法终止的
撤吊	行政许可依法被撤销、撤回，或许可证件依法被吊销的
不可抗	不可抗力导致行政许可事项无法实施的
兜底	法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形

【注】 撤销指该行政许可在实施时即有瑕疵；注销只是手续的办理问题，该许可 可能有瑕疵。

第三章 行政处罚法律制度 •

一、行政处罚的种类

（一）行政处罚的法定种类

行政处罚法规定的行政处罚种类	税务行政处罚的主要种类
1. 警告、通报批评 2. 罚款、没收违法所得、没收非法财物	1. 罚款

3. 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 4. 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、 限制从业 5. 行政拘留 6. 法律、行政法规规定的其他行政处罚	2. 没收违法所得 3. 停止出口退税权 4. 吊销税务行政许可证件（口诀：停吊罚没）

【注】 1. 加处罚款或滞纳金属于行政强制执行；征收国有土地上的房屋属于行政征收。

2. 不属于税务行政处罚的情形：

（1）属于行政处罚：如，警告、行政拘留、暂扣许可证件。

（2）属于行政命令，属于纠正违法行为本身的一种措施，不具有制裁性：责令 限期改正（包括责令停止税收违法行为、责令改正税收违法行为、责令限期进行纳税 调整等）。

（3）属于间接强制执行措施：收缴或者停售发票。

（4）税务具体管理行为：通知有关部门阻止出境、取消一般纳税人资格、收缴 税务登记证、停止抵扣等。

（二）行政处罚的理论分类

理论分类	法定分类
精神罚	警告、通报批评
财产罚	罚款、没收违法所得、没收非法财物
行为罚	暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件
	限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业
人身自由罚	行政拘留

【注】 1. 行政拘留与刑事拘留性质不同，行政拘留属于行政处罚，刑事拘留属于 刑事强制措施。

2. 注意区分行政处罚中的没收违法所得与刑罚种类中的没收财产。

二、行政处罚的设定

项目	创设权	具体规定权
法律	可设定各种行政处罚 【注】限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定	上位法有设定的，下位法不得再设定，但是下位法可以在上位法设定的范围内作出具体规定
行政法规	可设定除限制人身自由以外的行政处罚	
地方性法规	可设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚 【口诀】 “不能吊人”	
部门规章	警告、通报批评、一定数额罚款（国务院规定上限） 【口诀】 “部门精通罚”	
地方规章	警告、通报批评、一定数额罚款（省级人大常委会规定上限）	

【考点2】行政处罚听证程序(★★★)

1. 以当事人申请为前提；

2. 组织听证是一定条件下行政处罚实施机关的法定程序义务。

	行政处罚	税务行政处罚
听证的范围	1. 较大数额罚款 2. 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 3. 责令停产停业、责令关闭、限制从业 4. 吊销许可证件、降低资质等级 5. 其他较重的行政处罚 6. 法律、法规、规章规定的其他情形 罚款、没收、责令、吊销（比行 政处罚全部种类少了警报、暂扣、 拘留） 【口诀】“罚没责吊、罚没吊”	1. 罚款【公民 2000元以上（含本数）、 组织 10000 元以上（含本数）】 2. 没收较大数额违法所得 3. 吊销税务行政许可证件规律：罚款、没收、吊销（比一般行政处罚 的听证少了责令）

提出与通知	1. 当事人要求听证的，应当在行政机关告知后 5 日内提出，申请形式未明确规定 2. 举行期限未明确规定 3. 行政机关应当在举行听证的 7 日前将相关事项通知当事人	1. 要求听证的当事人，应当在《税务行政处罚事项告知书》送达后 5 日内向税务机关书面提出听证；逾期不提出的，视为放弃听证权利 2. 行政机关收到听证要求后 15 日内举行听证 3. 行政机关在举行听证的 7 日前将《税务行政处罚听证通知书》送达 当事人

	行政处罚	税务行政处罚
公开举行	除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行	
主持人与 当事人	1. 非本案调查人员主持 2. 当事人可以亲自参加，也可委托 1-2 人代理参加听证	
听证权利的放弃	当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听 证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证	
笔录	1. 听证应当制作听证笔录 2. 笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章 3. 当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔 录中注明（案卷制度）	1. 听证的全部活动，应当由记录员写成笔录，经听证主持人审阅并由 听证主持人和记录员签名后，封卷 上交税务机关负责人审阅 2. 听证笔录应交当事人或者其代理人、本案调查人员、证人及其他有 关人员阅读或者向他们宣读，他们 认为有遗漏或者有差错的，可以请 求补充或者改正。他们在承认没有 错误后，应当签字或者盖章 3. 拒绝签字或者盖章的，记明情况附卷

第四章 行政强制法律制度 •

【考点1】查封、扣押（★★★）

一、实施主体：法律、法规规定的行政机关实施。

【注】《税收征收管理法》38 条规定，税务机关依法享有扣押、查封纳税人的价 值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产的权利。

二、范围

1. 查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，不得查封、扣押与违法行为无关 的场所、设施或者财物；

2. 不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品；

3. 当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

三、程序

1. 行政机关决定实施查封、扣押的，应当依照法定程序进行，制作并“当场”交 付查封、扣押决定书和清单。

2. 查封、扣押决定书应当载明下列事项：

（1）当事人的姓名或者名称、地址；

（2）查封、扣押的理由、依据和期限；

（3）查封、扣押场所、设施或者财物的名称、数量等；

（4）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

（5）行政机关的名称、印章和日期。

四、时限

1. 查封、扣押的期限不得超过 30 日；

情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日； 法律、行政法规另有规定的除外。

【注】税务机关采取税收保全措施的期限一般不得超过 6 个月；重大案件需要延 长的，应当报国家税务总局批准。

2. 对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，查封、扣押的期间不包括 检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间应当明确， 并书面告知当事人。

3. 检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用“由行政机关承担”。

五、保管和赔偿

1. 对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或者 损毁；因未尽妥善保管义务造成损失的，应当承担赔偿责任。

2. 对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。

【注】因第三人的原因造成的损失，行政机关“先行赔付”后，有权向第三人追偿。

3. 因查封、扣押发生的保管费用“由行政机关承担”。

六、解除

1. 行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定的情形：

（1）当事人没有违法行为；

（2）查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；

（3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；

（4）查封、扣押期限已经届满。

2. 解除查封、扣押应当立即退还财物； 已将鲜活物品或者其他不易保管的财物拍 卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人 造成损失的，应当给予补偿。

【考点2】申请法院强制执行（★★★）

	申请条件： 当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政 决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 3 个月 内，申请法院强制执行

申请	催告： 行政机关申请法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向所在地有管辖权的法院 申请强制执行；执行对象是不动产的，向不动产所在地有管辖权的法院 申请强制执行
	申请材料： 1. 强制执行申请书 2. 行政决定书及作出决定的事实、理由和依据 3. 当事人的意见和行政机关催告情况 4. 申请强制执行标的情况 5. 法律、行政法规规定的其他材料
受理	法院接到申请，在 5 日内受理
	不予受理：15 日 +15 日 若行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在 15 日 内向上一级 法院申请复议，上一级法院应当自收到复议申请之日起 15 日 内作出是 否受理的裁定

审查	对符合法律规定，且行政决定具备法定执行效力的，法院自受理之日起 7 日内作出执行裁定
	因情况紧急，为保障公共安全，行政机关可以申请法院立即执行，经法 院院长批准，法院自作出执行裁定之日起 5 日内执行
执行费用	1. 行政机关申请法院强制执行，不缴纳申请费。强制执行的费用由被执 行人承担 2. 法院以划拨、拍卖方式强制执行的，可以在划拨、拍卖后将强制执行 的费用扣除。规律：执行费坏人担
	【注】行政强制措施的费用 1. 查封、扣押的标的物的检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政 机关承担

	2. 因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担

第五章 行政复议法律制度 •

【考点1】行政复议管辖(★★★)

一、县级以上地方各级政府的复议管辖范围

本级政府管辖	对本级政府工作部门作出的行政行为不服的
	对下一级政府作出的行政行为不服的
	对本级政府依法设立的派出机关（如街道办）作出的行政行为不服的
	对本级政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的 行政行为不服的
	省、自治区政府依法设立的派出机关（如阿里地区行政公署）参照设区 的市级政府的职责权限，管辖相关行政复议案件
	对县级以上地方各级政府工作部门依法设立的派出机构（如派出所、税 务所、财政所）依照法律、法规、规章规定，以派出机构的名义作出的 行政行为不服的行政复议案件，由本级政府管辖 【注】 本级政府或所在地政府管辖：对直辖市、设区的市政府工作部门 按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在 地的政府管辖
本机关 管辖	省、 自治区、直辖市政府同时管辖对本机关作出的行政行为不服的行政 复议案件
	对此行政复议决定不服，可以向法院提起诉讼，或向国务院申请最终裁决

二、国务院部门复议管辖范围

本机关 管	对本部门作出的行政行为不服的，对此行政复议决定不服，可以向法院 提起

辖	诉讼，或向国务院申请最终裁决
上级管辖	对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以 派出机构的名义作出的行政行为不服的，如国家金融监督管理总局在 31 个省、自治区、直辖市和 5 个计划单列市设立 36 个监管局
	对本部门管辖的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为 不服的

三、对垂直领导机关、税务和国家安全机关行政行为不服的复议管辖

垂直管辖	对海关、金融、外汇管理、税务和国安的行政行为不服的，向上一级主 管部门申请行政复议。【口诀】“海外金税安”

四、对司法行政部门行政行为不服的复议管辖

选择管辖	对履行行政复议职责的地方政府司法行政部门的行政行为不服的，可以 向本级政府或上一级司法行政部门申请行政复议 【例】 睢县司法局对没有取得律师职业证书的老刘以律师名义从事法律 服务业务，责令停止非法执业，没收违法所得 1 万元，罚款 1 万元

【考点2】行政复议决定（★★★）

种类	适用情形
维持决定	事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当
履行决定	针对不作为：被申请人没有履行法定职责，且履行还有意义，决定其在 一定期限内履行
变更决定	1. 事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，但是内容不适当 2. 事实清楚，证据确凿，程序合法，但是未正确适用依据（≠适用依据 错误，未正确使用包括违法适用、不当适用） 3. 事实不清、证据不足，经行政复议机关查清事实和证据

	【注】 行政复议机关不得作出对申请人更为不利的变更决定，但是第三人提出相反请求的除外
撤销决定	行政行为有下列情形之一的，行政复议机关决定撤销或者部分撤销该行政行为并可以责令被申请人在一定期限内重新作出行政行为 1. 主要事实不清、证据不足 2. 违反法定程序 3. 适用的依据不合法 4. 超越职权或者滥用职权 【注】 行政复议机关责令被申请人重新作出行政行为的，被中请人不得以同一事实和理由作出与被申请行政复议的行政行为相同或者基本相同的行政行为，但是行政复议机关以违反法定程序为由决定撤销或者部分 撤销的除外

种类	适用情形	
确认违法	能撤不撤	行政行为有下列情形之一的，行政复议机关不撤销该行政行 为，但是确认该行政行为违法： （1）依法应予撤销，但是撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害 （2）程序轻微违法、但是对申请人权利不产生实际影响
	不能撤	行政行为有下列情形之一，不需要撤销或者责令履行的，行政复议机关确认该行政行为违法： （1）行政行为违法，但是不具有可撤销内容 （2）被申请人改变原违法行政行为，申请人仍要求撤销或者确认该行政行为违法 （3）被申请人不履行或者拖延履行法定职责，责令履行没有意义

履行决定	被申请人不履行法定职责的，行政复议机关决定被申请人在一定期限内履行
确认无效	行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形申请人申请确认行政行为无效的，行政复议机关确认该行政行为无效
维持决定	行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的、 行政复议机关决定维持该行政行为
驳回行政复议请求	行政复议机关受理申请人认为被申请人不履行法定职责的行政复议申请 后，发现被申请人没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责的， 决定驳回申请人的行政复议请求（产驳回复议申请，驳回申请系用于不 满足受案条件的案件“纠错”）

第六章 行政诉讼法律制度 •

【考点1】行政诉讼被告（★★）

一、行政诉讼被告的特殊性

1. 对原告的诉讼请求没有反诉权。

2. 承担被诉行政行为合法性的举证责任。

3. 有权依法执行或者改变被诉的行政行为。

二、具体情形下被告资格的确定

（一）具体情形下被告资格的一般规定

实施主体	被告
上级行政机关批准的行政行为	署名机关
行政机关组建并赋予行政管理职能，但没有独立承担法律责任能力的机 构以自己名义作出	组建该机构的行政机关
授权的内设机构或派出机构、其他 组织，超出授权范围	实施该行为的机构或组织

行政机关委托的组织	委托的行政机关
被撤销或职权变更的行政机关	继续行使其职权的行政机关
	没有继续行使其职权的行政机关的，以其所属 的人民政府为被告；实行垂直领导的，以垂直领导的上一级行政机关为被告
开发区管理机构	1. 对由国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构作出的行政行为不服提起诉讼的， 以该开发区管理机构为被告 2. 国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构所属职能部门作出的行政行为的，其职能部门为被告 3. 其他开发区管理机构所属职能部门作出行政行为的，开发区管理机构为被告；开发区管理 机构没有行政主体资格的，设立该机构的地方 人民政府为被告
村民委员会、居民委员会、高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会依据法律、法规、规章的授权履行行政管理职责的行为	村民委员会或者居民委员会、高等学校等事业 单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协 会

【考点2】行政诉讼普通程序(★★)

行政行为	判决类型	适用情形
	驳回原告的诉讼请求	行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，人民法院判决驳回原告的诉讼请求

<table>
<tr><td rowspan="4">作为</td><td>撤销判决</td><td colspan="2">1. 主要证据不足的
2. 适用法律、法规错误的
3. 违反法定程序的
4. 超越职权的
5. 滥用职权的
6. 明显不当的
【注】 人民法院应当作出撤销判决，并可以判决被告重新 作出行政行为；被告不得以同一事实和理由作出与原行政 行为基本相同的行政行为</td></tr>
<tr><td rowspan="2">确认违法</td><td>应撤不撤</td><td>1. 行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、 社会公共利益造成重大损害的
2. 行政行为程序轻微违法（如处理期限轻徽违法、 通知或送达等程序轻微违法情形），但是对原告依 法享有的听证陈述、申辩等重要程序性权利不产生 实质损害的</td></tr>
<tr><td>撤无可撤</td><td>1. 行政行为违法，但不具有可撤销内容的
2. 被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的</td></tr>
<tr><td>变更判决</td><td colspan="2">行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、 认定确有错误的，人民法院可以判决变更。法院审理行政处罚案件时不得变更行政行为，加重对原告的处罚，包括加重处罚幅度或增加处罚内容；对行政机关未处罚的相对人，法院不得判决直接给予处罚
【注】人民法院判决变更，不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的 除外</td></tr>
</table>

	确认无效	行政行为重大且明显违法情形： 1. 行政行为实施主体不具有行政主体资格 2. 减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据 3. 行政行为的内容客观上不可能实施 4. 其他重大且明显违法的情形 【注】对于原告起诉请求确认无效或撤销行政行为，人民 法院经审查认为行政行为无效的，人民法院均应作出确认 无效判决

行政行为	判决类型	适用情形
不作为	履行判决	1. 原告请求被告履行法定职责的理由成立，被告违法拒绝履行或者无正当理由逾期不予答复的，人民法院可以判决被告 在一定期限内依法履行原告请求的法定职责；尚需被告调查 或者裁量的，应当判决被告针对原告的请求重新作出处理 2. 原告申请被告依法履行支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等给付义务的理由成立，被告依法负有给付 义务而拒绝或者拖延履行义务的，人民法院可以根据行政诉 讼法的规定，判决被告在一定期限内履行相应的给付义务
	确认违法	1. 被告不履行或者拖延履行法定职责，判决履行没有意义的 2. 原告起诉被告不作为，在诉讼中被告作出行政行为，原告不撤诉的，人民法院应当继续审查被告的不作为是否合法
	驳回原告的诉讼请求	原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立的， 人民法院判决驳回原告的诉讼请求
	裁定驳回起诉	1. 原告请求被告履行法定职责或者依法履行支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等给付义务，原告未先向行政机关提出请求或者申请的，人民法院裁定驳回起诉 2. 人民法院经审理认为原告所请求履行的法定职责或者给付义务明显不属于行政机关权限范围的，可以裁定驳回起诉

【注】人民法院判决确认违法或者无效的， 可以同时判决责令被告采取补救措施； 给原告造成损失的，依法判决被告承担赔偿责任。

四、简易程序

1. 人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

（1）被诉行政行为是依法当场作出的；

（2）案件涉及款额 2000 元以下的；

（3）属于政府信息公开案件的；

（4）当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。

2. 适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起 45 日内审结。

3. 适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经 人民法院准许，但不得超过 15 日。

4. 人民法院在审理过程中，发现案情复杂、不宜适用简易程序的，裁定转为普通 程序。

第七章 民法总论

【考点1】民事法律事实（★★）

民事法律事实，是指能引起民事法律关系发生、变更和消灭的客观事实。

一、民事法律事实的分类

（一）自然事实，是指与人的意志无关的法律事实，包括事件和状态。

项目	内容	
事件	某种客观现象的发生	如：人的出生、死亡，自然灾害的发生等
状态	某种客观现象的持续	如：自然人的下落不明、时间的经过等

（二）行为，是指人的有意识的活动。

标准	分类	概念（示例）
内容和形式是否合	合法行为	符合法律规定、受法律确认和保护的行为 例：生效法律行为、正当防卫、紧急避险等

法	不法行为	不符合法律要求或者违反法律规定的行为 例：违约行为、侵权行为等
是否以行为人的意思表示为要件	表意行为	法律行为：指以意思表示为核心要素，如，合同、代理
		准法律行为：指由法律直接规定民法效果的表意行为，包括意思通知（如要约拒绝、履行催告）、观念通知（如承诺迟到通知、债权让与通知）和情感表示（如被继承人对继承人的宽恕）
	非表意行为（事实行为）	无须表示内心意思即依法发生法律效果的行为 例：建造房屋、作品创作行为、拾得遗失物、先占、无因 管理、不当得利、侵权行为等

二、法律事实构成

法律事实构成，是指须同时具备方能引起某一民事法律关系发生、变更或者消灭 的几个法律事实的总和。

【注】遗嘱继承关系的发生：

既需要有效的立遗嘱行为，同时又需要有遗嘱人死亡的事件，两个法律事实结合， 即为法律事实构成。

【考点2】自然人的民事行为能力(★★)

完全民事行为能力人	标准：≥ 18 周岁 /（16 ≤ X<18+ 能以自己的劳动收入作为主要生 活来源） 行为能力：能够独立实施任何民事法律行为
限制民事行为能力人	标准：8 ≤ X<18 周岁 / 不能完全辨认自己行为的成年人 行为能力：仅能实施与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事 法律行为以及纯获利益的民事法律行为
无民事行为能力人	标准：<8 周岁 / 不能辨认自己行为的成年人、未成年人 行为能力：须由其法定代理人代理实施民事法律行为

【考点3】民事法律行为的效力样态(★★★)

一、完全生效民事法律行为

1. 完全生效民事法律行为可以按照意思表示的内容发生行为人预期的民法效果。

2. 民事法律行为自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

二、尚未完全生效民事法律行为

1. 尚未完全生效民事法律行为，亦称“待生效民事法律行为”，是指存在法定或者约定的特别生效要件，而该特别生效要件尚未成就的民事法律行为。

2. 尚未完全生效的民事法律行为

项目	内容
尚未满足法定特别生效 要件的民事法律行为	如，法律、行政法规规定须办理批准等手续方能生效的民事法律行为，尚未办理批准等手续
尚未满足约定特别生效 要件的民事法律行为	如，附停止条件或附始期的民事法律行为，所附停止条 件尚未成就或所附期限尚未届至

三、可撤销民事法律行为

（一）定义

存在法定的重大意思表示瑕疵而可以请求法院或仲裁机构予以撤销的民事法律行 为。

（二）可撤销民事法律行为类型

1. 基于重大误解所实施的民事法律行为。

【注】行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、 数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识，行为人就不会作出相应意思表示的，可以认定为重大误解。

2. 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。

3. 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为， 且对方知道或者应当知道该欺诈行为的。

4. 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律 行为。

5. 一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形所实施的显失公平的民事法 律行为。

6. 行为人的意思表示存在第三人转达错误情形下所实施的民事法律行为。

（三）撤销权的消灭

项目	内容	
消灭情形	一般	主观标准：知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行 使撤销权
	重大误解	主观标准：知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行 使撤销权
	胁迫	胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权
	放弃	当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃 撤销权的
	5 年	当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的

四、效力待定民事法律行为

（一）定义

民事法律效力有待第三人以行为使之确定的民事法律行为。

（二）类型

1. 无权处分。

2. 狭义无权代理。

3. 债务承担。

4. 限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的、有待 其法定代理人同意或者追认的民事法律行为。

【注】 相对人（不论是否善意）可以催告法定代理人自收到通知之日起 30 日 内 予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

五、无效民事法律行为

（一）效力

自始、确定、当然的不发生固有效力。

（二）情形（有硬伤）

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为。

2. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为。

【注】恶意串通，是指行为人与相对人为牟取私利而相互勾结致害他人。

3. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为。

【注】 行为人与相对人以虚假的意思表示所隐藏的民事法律行为有效与否，应当依据相关法律规定予以判断。

4. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为，但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

【注】此处的“强制性规定”限于“效力性强制性规定”。

效力性强制性规定主要包括：

（1）涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策的；

（2）交易标的禁止买卖的，如禁止人体器官、毒品、枪支等买卖；

（3）违反特许经营规定的，如场外配资合同；

（4）交易方式严重违法的，如违反招投标等竞争性缔约方式订立的合同；

（5）交易场所违法的，如，在批准的交易场所之外进行期货交易。

5. 违背公序良俗的民事法律行为。

【注】根据裁判实务归纳的违背公序良俗的行为类型主要包括：

（1）影响政治安全、经济安全、军事安全等国家安全类型；

（2）影响社会稳定、公平竞争秩序或者损害社会公共利益等违背社会公共秩序 类型；

（3）背离社会公德、家庭伦理或者有损人格尊严等违背善良风俗类型。

【考点4】无权代理(★★)

<table>
<tr><td>狭义无权代理 （效力待定的民事法律行为）</td><td colspan="2">1. 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实 施代理行为未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力
2. 相对人可以催告被代理人自收到通知之日起 30 日 内予以追 认。被代理人未作表示的、视为拒绝追认。行为人实施的行为 被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式 作出
3. 行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。但是，赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益
4. 相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任</td></tr>
<tr><td rowspan="4">表见代理</td><td colspan="2">行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施 代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效</td></tr>
<tr><td>授权表示型表见代理</td><td>代理人虽事实上未获授权，但存在使相对人善 意信赖其具有代理权外观而实施的无权代理</td></tr>
<tr><td>权限逾越型表见代理</td><td>代理人超越代理权限范围且存在使相对人善意 信赖其未超越代理权限外观而实施的无权代理</td></tr>
<tr><td>权限延续型表见代理</td><td>代理人在代理期限届满后、或者约定的代理事 务完成后、或者代理权被撤销后，且存在使相 对人善意信赖其仍具有代理权外观所实施的无 权代理</td></tr>
<tr><td>表见代理构成要件</td><td colspan="2">1. 行为人无代理权但以本人（被代理人）名义实施民事法律行 为（本质上的无权代理）
2. 须客观上存在使相对人相信行为人有代理权的表征（具有有权代理的“外观” ）
3. 相对人须为善意，即无过失地不知行为人无代理权
4. 具备民事法律行为的生效要件</td></tr>
</table>

有理由相信	同时符合下列条件的，人民法院可以认定为民法典规定的相对 人有理由相信行为人有代理权： 1. 行为人存在具有代理权的外观 2. 相对人无过失地不知道行为人行为时没有代理权

第八章 物权法

【考点1】善意取得制度(★★)

适用条件	1. 转让人无权处分 2. 受让人受让该不动产或者动产时是善意的 3. 以合理的价格受让 4. 转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要 登记的已经交付给受让人 5. 转让合同有效
法律后果	受让人取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权 人请求损害赔偿
善意认定	受让人受让时，不知道转让人无处分权且无重大过失
举证责任	真实权利人承担举证证明责任
不动产受让人恶意认定	应当认定不动产受让人知道转让人无处分权情形： 1. 登记簿上存在有效的异议登记 2. 预告登记有效期内，未经预告登记的权利人同意 3. 登记簿上已经记载司法机关或者行政机关依法裁定、决定查封或者 以其他形式限制不动产权利的有关事项 4. 受让人知道登记簿上记载的权利主体错误 5. 受让人知道他人已经依法享有不动产物权
重大过失 认定	1. 真实权利人有证据证明不动产受让人应当知道转让人无处分权 2. 受让动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的

善意时间	1. 简易交付：转让动产法律行为生效时 2. 指示交付：转让返还原物请求权的协议生效时
交付取得	船舶、航空器和机动车等特殊动产的善意取得
善意取得的排除适用	1. 转让合同被认定无效 2. 转让合同被撤销

【考点2】共有（★★★）

共有形态	按份共有	共有人按各自确定的份额享有所有权。（享多大权利，担多大义务） 【注】非家庭成员：无约定，就按份 份额的判断：约定→ 出资额→等额，大家依份额享有所有权
	共同共有	1. 数人对同一物平等和不分份额地共同享有所有权（有福同享， 有难同当） 2. 需以共同关系的存在为前提 【注】家庭成员：无约定，就共同
	共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或 者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有	
共有份额	按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额，没有约定或者约定不 明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视为等额享有（约定→ 出资额→等额享有）	
处分、重大修缮共有物	处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、 变更性质或者用途的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人或者全体共 同共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外（约定→ >213 份额按份 共有人 / 全体共同共有人）	
因共有物产生的债权债务	对外	共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第 三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外
	对内	除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务，共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿（约定一份额 /共同）
设定担保	按份共有人可在其共有份额上设定担保物权	

【考点3】共有份额转让(★★★)

转让规则	按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人 在同等条件下享有优先购买的权利（不需要征得其他按份共有人同意） 【注】 “同等条件”，应当综合共有份额的转让价格、价款履行方式 及期限等因素确定
优先购买权排除适用	1. 共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共 有人主张优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外（约 定一排除适用） 2. 按份共有人之间转让共有份额，其他按份共有人主张依据规定优先购买的不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外（约定一排除适用）

通知	按份共有人转让其享有的共有的不动产或者动产份额的，应当将转让 条件及时通知其他共有人
优先购买权行使期间	优先购买权的行使期间，按份共有人之间有约定的，按照约定处理； 没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定： 1. 转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行 使期间的以该期间为准 2. 通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起 15 日的，为 15 日 3. 转让人未通知的，为其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的 同等条件之日起 15 日 4. 转让人未通知，且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终 确定的同等条件的，为共有份额权属转移之日起 6 个月
优先购买权被损害	其他按份共有人以其优先购买权受到侵害为由，仅请求撤销共有份额 转让合同或者认定该合同无效的，人民法院不予支持

优先购买权行使规则	1. 两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买 比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权（协商→转让时共有份额比例） 2. 其他按份共有人未在约定或法定的期间内主张优先购买，或者虽主张优先购买但提出减少转让价款、增加转让人负担等实质性变更要求， 人民法院不予支持

【考点4】抵押权（★★）

一、可以抵押的财产 VS 不得抵押的财产

可以抵押	不得抵押
1. 建筑物和其他土地附着物 2. 建设用地使用权 3. 海城使用权 4. 生产设备、原材料、半成品、产品 5. 正在建造的建筑物、船舶、航空器 6. 交通运输工具 7. 法律、行政法规未禁止抵押的其他	1. 土地所有权 2. 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外 3. 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施 4. 所有权、使用权不明或者有争议的财产 5. 依法被查封、扣押、监管的财产 6. 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产

二、抵押权的效力

（一）范围

有约定按约定，没有约定包括“主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押 权的费用”

（二）抵押权所及标的物的范围

抵押权及于抵押财产本身及其从物、从权利；及于抵押财产被法院依法扣押期间产 生的孳息；及于抵押财产因加工、附合、混合形成的添附物；及于抵押财产因侵权行为、 保险事故、征收、添附等原因毁损、灭失所获得的赔偿金、补偿金、保险金等代位物。

（三）抵押权人的权利

变价处分权；优先受偿权；保全抵押财产价值权；抵押权的处分权。

（四）抵押人的权利

1. 抵押财产的用益权。

抵押权设立后，抵押人仍保有对抵押财产的占有，仍可以对抵押财产进行使用和 收益。

2. 抵押财产的处分权。

（五）重复抵押时的清偿顺序

1. 已登记的，优于未登记的清偿：登记 > 未登记；

2. 均已登记的，按照登记时间的先后顺序清偿；

3. 未登记的，按债权比例清偿（不是按抵押合同订立的先后）。

（六）抵押权的物上代位效力

担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、 赔偿金或者补偿金等优先受偿。

被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

（七）抵押权的追及效力

抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财 产转让的，抵押权不受影响。抵押权追及效力的法律限制：

1. 善意取得制度：第三人善意取得抵押财产的，可以阻断抵押权的追及效力。

2. 抵押权未按法定方式公示：未按法定方式公示的抵押权不得对抗善意第三人。

3. 正常经营买受人规则：以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理 价款并取得抵押财产的买受人。

【注】买受人在出卖人正常经营活动中通过支付合理对价取得已被设立担保物权 的动产，担保物权人请求就该动产优先受偿的，人民法院不予支持，但是有下列情形 之一的除外：

（1）购买商品的数量明显超过一般买受人；

（2）购买出卖人的生产设备；

（3）订立买卖合同的目的在于担保出卖人或者第三人履行债务；

（4）买受人与出卖人存在直接或者间接的控制关系；

（5）买受人应当查询抵押登记而未查询的其他情形。

（八）抵押权的优先效力

1. 一般规则：（登记）时间在先，效力优先。

2. 特殊规则：购置款超级优先权

动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的， 该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

【注】担保人在设立动产浮动抵押并办理抵押登记后又购入或者以融资租赁方式 承租新的动产，下列权利人为担保价款债权或者租金的实现而订立担保合同，并在该 动产交付后 10 日内办理登记，主张其权利优先于在先设立的浮动抵押权的，人民法 院应予支持

（1）在该动产上设立抵押权或者保留所有权的出卖人；

（2）为价款支付提供融资而在该动产上设立抵押权的债权人；

（3）以融资租赁方式出租该动产的出租人。

同一动产上存在多个价款优先权的，人民法院应当按照登记的时间先后确定清偿 顺序。

【考点5】数种担保并存时的效力(★★)

并存	处理
意定担保物权并存	同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的 价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序
	动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办 理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权 人受偿，但是留置权人除外（价款优先权 / 超级优先抵押权）
意定 + 法定担保物权	同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权 人优先受偿

【考点6】占有效力(★★★)

对权利人 的保护	1. 不动产或者动产被占有人占有的，权利人可以请求返还原物及其孳息，但应当支付善意占有人因维护该不动产或者动产支出的必要费用 2. 占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损 害的，恶意占有人应当承担赔偿责任

对占有的保护	1. 对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险 2. 占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起 1 年内未行使的，该请求权消灭（该 1 年为除斥期间） 3. 因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿

第九章 债法

【考点1】债的发生原因（★★★）

合同 （意定之债）	1. 合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议 2. 合同之债属于意定之债，具有任意性 3. 合同由双方民事法律行为引起，但合伙合同由共同法律行为引起，基于多方当事人意思表示一致而成立，且多方当事人意思表示的内容相同
缔约过失 （法定之债）	当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任： 1. 假借订立合同，恶意进行磋商 2. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 3. 泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息 4. 有其他违背诚信原则的行为
单方允诺 （意定之债）	1. 单方允诺，是指表意人向相对人作出的，为自己设定某种义务，使相对人取得某种权利的意思表示，如悬赏广告：悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付 2. 单方允诺是表意人向不特定相对人发出的要约，相对人践行允诺内容则构成承诺，表意人与相对人之间的债权债务关系于相对人践行允诺内容之时发生
侵权行为 （法定之债）	侵权行为，是指不法侵害他人民事权益造成损害，依法应当承担民事责任的致害行为。被侵权人有权请求侵权人予以赔偿，侵权人也应当向被侵权人进行赔偿双方因此形成以损害赔偿为主要内容的债权债务关系

【考点2】无因管理（★★★）

含义	1. 管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损而管理他 人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理 人因管理事务受到损失的、可以请求受益人给予适当补偿；管理人因 管理事务负担必要债务的，有权请求被管理人清偿 2. 管理事务不符合受益人真实意思的，管理人不享有必要费用偿还请 求权；但是，受益人的真实意思违反法律或者违背公序良俗的除外	
构成要件	1. 管理人管理他人事务 2. 管理人具有为他人利益而管理的意思 3. 管理人对本人无法定或约定的义务	
单方允诺（意定之债）	1. 管理人管理他人事务 2. 管理人具有为他人利益而管理的意思 3. 管理人对本人无法定或约定的义务	
适当管理义务	管理人管理他人事务，应当采取有利于受益人的方法。中断管理对受 益人不利的，无正当理由不得中断	
通知义务	管理人管理他人事务，能够通知受益人的，应当及时通知受益人。管 理的事务不需要紧急处理的，应当等待受益人的指示	
报告和交付义务	管理结束后，管理人应当向受益人报告管理事务的情况。管理人管理 事务取得的财产，应当及时转交给受益人	
准合同效力转换	管理人管理事务经受益人事后追认的，从管理事务开始时起，适用委 托合同的有关规定，但是管理人另有意思表示的除外（效力追溯至管 理事务开始时）	
不真正无因管理	误信管理	误将他人事务当作自己事务进行管理（欠缺“为他人管理” 主观要件，不成立无因管理，可能成立不当得利或侵权行为）
	不法管理	明知是他人事务，却为自己利益进行管理（欠缺“为他人管理”主观要件，不成立无因管理）

	幻想管理	误将自己事务当作他人事务进行管理（欠缺“管理他人事务” 客观要件，不成立无因管理）

【考点3】不当得利（★★★）

含义	得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人 返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外： 1. 为履行道德义务进行的给付 2. 债务到期之前的清偿 3. 明知无给付义务而进行的债务清偿 【注】不当得利属于法律事实中的事件范畴（2025 年新增）
构成要件	1. 一方获得财产利益 2. 他方受有损失 3. 获得利益与受有损失之间存在因果关系 4. 一方获得利益没有合法根据
给付不当得利（因给付而受利益）	1. 因法律行为无效、不成立、被撤销、不被追认而发生的不当得利 2. 因合同解除而发生的不当得利 3. 因非债清偿而发生的不当得利 4. 因合同所附解除条件成就而发生的不当得利 5. 因合同所附终期届至而发生的不当得利
非给付不当得利（因给付以外事由而受利益）	1. 行为 （1）受益人的行为（如税务机关多收税款） （2）受损人的行为（如纳税人多缴税款） （3）第三人的行为（如送报员将甲订的报纸投入乙的报箱） 2. 自然事件（如因连降暴雨致鱼塘水位升高，甲鱼塘中的鱼跃入相 邻的乙鱼塘中） 3. 法律的直接规定（如基于添附而发生的不当得利）
受损人的利益返还请求权	受损人有权请求得利人返还其所取得的不当利益

返还义务	善意得利人	得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，仅返还现存利益。取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务
	恶意得利人	得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失
	第三人	得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的 人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务

【考点4】债的分类（★★★）

根据债的发生原因	意定之债	合同（双方法律行为）、遗赠（单方法律行为）
	法定之债	缔约过失之债、侵权行为之债、无因管理之债、不当得利 之债
根据 给付标的	实物之债	指以实物作为给付标的的债
	货币之债（金钱之债）	以给付一定数额的货币为标的的债
	利息之债	以给付利息为标的的债
	劳务之债	以债务人提供劳务为给付标的的债，如演出合同、雇佣合同
	权利之债	以特定的权利为给付标的的债，包括物权、债权、知识产权
	损害赔偿之债	以赔偿他人所受损害为标的的债，如侵权行为，不履行债务
根据双方主体人数	单数主体之债	债权人与债务人各为一人的债
	复数主体之债	当事人一方或双方为两人或两人以上的债
复数主体之债中，多数债权人或多数债务人对外关系	按份之债	各自按照一定的份额享有债权或负担债务的债
	连带之债	1. 各债权人均得请求债务人为全部债务的履行，各债务人均负有为全部履行的义务 2. 全部债权债务关系因一次全部给付而归于消灭的债 【注】其产生只能依据当事人的约定或法律规定

连带之债的效力：

1. 连带债务人之间的份额难以确定的，视为份额相同

2. 实际承担债务超过自己份额的连带债务人，有权就超出部分在其他连带债务人未 履行的份额范围内向其追偿，并相应地享有债权人的权利，但是不得损害债权人的 利益。其他连带债务人对债权人的抗辩，可以向该债务人主张

3. 部分连带债务人履行、抵销债务或者提存标的物的，其他债务人对债权人的债务 在相应范围内消失

4. 部分连带债务人的债务被债权人免除的，在该连带债务人应当承担的份额范围内， 其他债务人对债权人的债务消灭

5. 部分连带债务人的债务与债权人的债务同归于一人的，在扣除该债务人应当承担 的份额后，债权人对其他债务人的债权继续存在

6. 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，对其他连带债务人也发生受领延迟 的效力

7. 连带债权人之间的份额难以确定的，视为份额相同

8. 实际受领债权的连带债权人，应当按比例向其他连带债权人返还

3. 不真正连带债务，是指多数债务人就基于不同发生原因而偶然产生的同一内容的给付，各负全部履行的义务，并因债务人之一的履行而使全体债务人的债务均归于 消灭的多数人之债。（谁赔都行）

《民法典》第 1203 条规定，因产品存在缺陷造成他人损害，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生者造成的，销售 者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的， 生产者赔偿后， 有权向销售者追偿。该规定中，生产者和销售者对被侵权人承担的即为不真正连带债务

复数主体之债的标的是否可分	可分之债	以同一可分给付为标的，其债权可分享或其债务可分担的 复数主体之债。如数人共同侵权之债
	不可分之债	同一不可分给付为标的的复数主体之债，即数人共负同一 债务或者共享同一债权，而其给付不可分。如数人共同承 租一套公寓
	简单之债	债的标的只有一宗，当事人只能按该宗标的履行的债

标的可否选择	选择之债	债的标的有数宗，当事人可以选择其中之一为履行标的， 如定金和违约金选择其一
	任意之债	指债权人或债务人可以约定用原定给付之外的其他给付来代替原定给付的债，如双方约定应交付冰箱一台，但可 以用一台洗衣机代替
根据两债之间的主从关系	主债	能够独立存在的债
	从债	从属于主债且效力受主债影响的债
根据债的**给付方法**	一时之债	只须一次给付或分期给付即可完成的债，如买卖合同
	持续之债	以持续性给付为标的的债，如租赁合同、保管合同

【考点5】债的担保（★★）

一、保证

（一）保证的概念

1. 含义

指第三人与债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时， 由第三人按照约定履行债务或者承担责任的担保方式。

2. 不能做保证人

（1）机关法人 （但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转 贷的，国家机关可以为保证人）。

（2）以公益为目的的非营利法人、非法人组织。

（二）保证的特征

1. 从属性；2. 补充性；3. 独立性

（三）保证的成立和担保范围

1. 保证的成立

保证基于保证合同而成立。保证合同，是指为保障债权的实现，保证人和债权人 约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者 承担责任的合同。

保证合同属于单务、无偿、诺成、要式合同以及从合同。

2. 保证的担保范围

保证的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用； 当事人另有约定的，按照其规定。

3. 保证合同的形式——书面形式

（1）债权人与保证人单独订立书面保证合同；

（2）主债权债务合同中的保证条款；

（3）第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的。

4. 保证的方式

分为：一般保证和连带责任保证

一般保证	1. 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证 责任的保证方式。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并 就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任（先诉抗辩权），但是有下列情形之一的除外： （1）债务人下落不明，且无财产可供执行 （2）人民法院已经受理债务人破产案件 （3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债 务能力 （4）保证人以书面形式放弃先诉抗辩权 2. 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任

连带保证	1. 指当事人在合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的保证方式 2. 连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时， 债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担 保证责任
数人保证	同一债务有 2 个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任；没有约定保证份额的，债权人可以请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任
最高额保	保证人与债权人可以协商订立最高额保证的合同，约定在最高债权额限度 内就

证	一定期间连续发生的债权提供保证

5. 保证人的抗辩权

（1）主债务人的抗辩权。主债权债务合同中，债务人所享有的一切抗辩权保证人均可以行使。保证人可以主张债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的，保证人仍有权向债权人主张抗辩。债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的，保证人可以在 相应范围内拒绝承担保证责任。

（2）保证人自身的抗辩权。这是基于保证合同自身所产生的，由保证人独享的 抗辩权。如保证期间届满的抗辩权、保证合同诉讼时效完成的抗辩权等。

（3）一般保证中，保证人的先诉抗辩权。

6. 保证期间

含义	1.保证期间，是确定保证人承担保证责任的期间，是不变期间，不发生中止、中断和延长 2. 债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任 （1）一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的， 保证人不在承担保证责任 （1）连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的， 保证人不再承担保证责任
保证期间确定	1. 可以约定保证期间 2. 债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者 约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月 3. 债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期 间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算

7. 保证合同的诉讼时效

一般保证	一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的， 从保证人拒绝承担保证责任的权利（先诉抗辩权）消灭之日起，开始计算 保证债务的诉讼时效
连带保证	连带责任保证的债权人在保证期间届满前，请求保证人承担保证责任的， 从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证债务的诉讼时效

8. 主债权债务合同变更对保证责任的影响

（1）债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

（2）债权人与债务人对主债权债务合同履行期限作了变更，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响。

（3）债权人将全部或者部分债权转让，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。保证人与债权人约定禁止债权转让，债权人未经保证人书面同意转让的，保证人对受让人不再承担保证责任。

（4）债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和保证人另有约定的除外。 第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

二、定金

1. 定金合同是实践合同，以定金的交付作为生效要件。定金合同自实际交付定金时成立。

2. 定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产 生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金 数额。

3. 定金与预付款的区别

（1）单纯的预付款不起担保作用，而定金具有担保作用。

（2）交付定金是成立定金合同的要件，而交付预付款是合同履行的一部分。

（3）定金适用“定金罚则”，而预付款不适用。

（4）定金不仅适用以金钱履行义务的合同，还适用其他合同，而预付款只能适 用以金钱履行义务的合同。

（5）定金一般一次性交付，而预付款可以分期交付。

4. 定金与违约金的区别

（1）定金是在履行之前交付，而违约金是在违约之后交付。

（2）定金有证约和预先给付作用，违约金没有。

（3）定金既是担保方式也是违约责任的承担方式，违约金仅是违约责任的承担方式。

（4）定金的数额法律保护有上限限制，违约金则无。

5. 定金的类型

定金基于功能的不同而被分为违约定金、立约定金、成约定金和解约定金等类型。

《合同编通则解释》第 67 条规定，当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、 押金或者订金等，但是没有约定定金性质，一方主张适用《民法典》第 587 条规定的 定金罚则的，人民法院不予支持。

当事人约定了定金性质，但是未约定定金类型或者约定不明， 一方主张为违约定金的，人民法院应予支持。

当事人约定以交付定金作为订立合同的担保，一方拒绝订立合同或者在磋商订立合同时违背诚信原则导致未能订立合同，对方主张适用《民法典》第 587 条规定的定 金罚则的，人民法院应予支持。

当事人约定以交付定金作为合同成立或者生效条件，应当交付定金的一方未交付定金，但是合同主要义务已经履行完毕并为对方所接受的，人民法院应当认定合同在对方接受履行时已经成立或者生效。

当事人约定定金性质为解约定金，交付定金的一方主张以丧失定金为代价解除合同的，或者收受定金的一方主张以双倍返还定金为代价解除合同的，人民法院应予支持。

6. 定金罚则，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金； 收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

《合同编通则解释》第 68 条规定，双方当事人均具有致使不能实现合同目的的违约行为，其中一方请求适用定金罚则的，人民法院不予支持。

当事人一方仅有轻微违约，对方具有致使不能实现合同目的的违约行为，轻微违约方主张适用定金罚则，对方以轻微违约方也构成违约为由抗辩的，人民法院对该抗辩不予支持。

当事人一方已经部分履行合同，对方接受并主张按照未履行部分所占比例适用定金罚则的，人民法院应予支持。对方主张按照合同整体适用定金罚则的，人民法院不 予支持，但是部分未履行致使不能实现合同目的的除外。

因不可抗力致使合同不能履行，非违约方主张适用定金罚则的，人民法院不予支持。

7. 定金的效力

（1）证约效力。给付定金后，如无相反证据，主合同视为成立。定金具有证明 主合同成立的效力。

（2）充抵价金和返还效力。主债履行后，定金作为从债即告消灭。给付定金的当事人一方，可以请求接受定金的当事人一方返还其定金或者请求以定金充抵应付之价金。

（3）利益填补效力。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债 务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。此即所谓的“定金罚则”。

（4）替代赔偿金效力。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求 赔偿超过定金数额的损失。

（5）违约定金效力。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方 可以选择适用违约金或者定金条款。可见，定金也可以作为违约责任的承担方式。

【考点6】债的消灭（★★）

一、清偿

<table>
<tr><td rowspan="4">清偿地</td><td rowspan="3">清偿地可由双方合意选 择确定，也可依给付的性质确定。若双方没有 约定或者约定不明确的， 则根据《民法典》确定</td><td>给付货币的</td><td>在接受货币一方所在地履行</td></tr>
<tr><td>交付不动产的</td><td>在不动产所在地履行</td></tr>
<tr><td>其他给付</td><td>在履行义务一方所在地履行</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 当事人有约定的，从其约定
2. 当事人未约定或者约定不明确的：债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间</td></tr>
<tr><td>清偿</td><td colspan="3">清偿费用由债务人承担。但因债权人原因增加的清偿费用， 由债权人承担。</td></tr>
</table>

费用	法律有特别规定或者当事人有特别约定除外
清偿人	基于法律规定或者合同约定，清偿可以由第三人进行；若第三人的清偿能 使债权人得到满足，且对债权人并无不利时，第三人的清偿应为有效，债权人无正当理由不得拒绝 1. 由第三人履行，当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行 债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任（相对性） 2. 第三人代为履行，债务人不履行债务，第三人对履行该债务具有合法利益的，第三人有权向债权人代为履行；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，但是债务人和第三人另有约定的除外。 由此可见，第三人代为清偿后即发生法定的债权让与（所有权人赎回留置物）
清偿抵充	是指债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以 清偿全部债务时，确定该给付抵充数项债务中某项或者某项债务的清偿规则。（确定钱还的是哪一笔） 1. 债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以清 偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在清偿时指定其履行的债 务（债务人指定） 2. 债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；数项债务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务；均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，按照债务比例履行（已到期 →无担保→ 负担 重→到期在先→ 比例） 3. 债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行： （1）实现债权的有关费用 （2）利息 （3）主债务

二、抵销

<table>
<tr><td>法定抵销
应具备条件</td><td colspan="2">1. 须双方互享债权、互负债务
2. 须双方互负债务属于同一种类
3. 须双方债权均届满清偿期
4. 须债权债务依其性质或者法律规定可以为抵销</td></tr>
<tr><td>合意抵销的
要件及效力</td><td colspan="2">可由当事人自由商定，且不受法定抵销要件的约束</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抵销的方法 和
效力</td><td>法定抵销</td><td>当事人主张抵销的，应当通知对方；通知自到达对方时 生效。抵销不得附条件或者附期限。</td></tr>
<tr><td>合意抵销</td><td>自双方达成抵销合意时生效，双方对等数额的债权债务 即归于消灭</td></tr>
</table>

三、提存

（一）发生原因

1. 债权人无正当理由拒绝受领；
2. 债权人下落不明；
3. 债权人死亡未确定继承人、遗产管理人或者丧失民事行为能力未确定监护人
4. 法律规定的其他情形

（二）效力

1. 自提存之日起，债权人与债务人之间的债权债务关系归于消灭；
2. 提存物的所有权自提存之时起移转于债权人；
3. 提存物在提存期间所产生的孳息归债权人所有；
4. 提存物在提存期间毁损、灭失的风险由债权人承担；
5. 提存费用由债权人承担；
6. 债权人可以随时领取提存物。债权人领取提存物的权利，自提存之日起 5 年内 不行使而消灭，扣除提存费用归国家所有。

四、免除

1. 免除作为法律行为，可以附条件，也可以附期限。

2. 债权人免除债务人部分或者全部债务的，债权债务部分或者全部终止，但是债 务人在合理期限内拒绝的除外。

五、混同

1. 债权人和债务人归于一人。如继承、企业合并

2. 债权和债务同归于一人的，债权债务终止，但是损害第三人利益的除外

【考点7】债的保全（★★★）

一、代位权

（一）债权人代位权的行使条件

1. 债务人怠于行使其债权以及与该债权有关的从权利。

【注】 “怠于行使”权利是指债务人不履行其对债权人的到期债务，又不以诉讼 或仲裁方式向相对人主张其享有的债权或者与该债权有关的从权利。

2. 须有保全到期债权的必要。

3. 须债权人的债权已届履行期。

【注】法律另有规定的，不受“到期”条件限制。

如民法典规定，债权人的债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利 存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形，影响债权人的债权实现 的，债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者 作出其他必要的行为。

（二）债权人代位权的行使

代位权的行使	具体规定
行使方法	必须通过诉讼方式行使
行使范围	以债务人的债权额和债权人的债权额为限
行使权利	以非专属于债务人自身的权利为限
行使费用	债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担

【注】专属于债务人自身的权利包括：

1. 抚养费、赡养费或者扶养费请求权；

2. 人身损害赔偿请求权；

3. 劳动报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；

4. 请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生 活的权利；

5. 其他专属于债务人自身的权利。

（三）债权人代位权行使的效力

1. 债权人接受债务人的相对人履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相 应的权利义务终止。

2. 相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。

二、撤销权

（一）债权人撤销权的行使条件

1. 须有债务人将财产赠与他人、放弃债权、为他人债务提供担保、放弃债权担保、 恶意延长到期债权的履行期限、以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价 受让他人财产、以明显不合理的价格实施互易财产、以物抵债、出租或者承租财产、知识产权许可使用等减少其财产或者增加其财产负担的行为。

【考点8】合同的订立（★★★）

合同的订立，从法律上可分为要约与承诺两个阶段。

一、要约

（一）概念与构成要件

	定义	判断要点
要约	希望和他人订立合同的意思表示	1. 要约须是特定人作出的意思表示 2. 要约须向要约人希望与之订立合同的相对人发出 3. 要约内容须具体明确 4. 要约须是受相对人承诺拘束的意思表示
要约邀请	希望他人向自己发	拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招 募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。 商业

	出要约	广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约

（二）要约的生效时间

以对话方式作出的要约	受要约人知道其内容时生效
以非对话方式作出的要约	到达受要约人时生效
以非对话方式作出的采用数据电文形式的要约	指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定 系统时生效
	未指定特定系统的，受要约人知道或应当知道该数据电 文进入其系统时生效

（三）要约的撤回与撤销

撤回	1. 指要约在发生法律效力（到达）之前，欲使其不发生法律效力而取消要约 的意思表示 2. 撤回通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人
撤销	1. 撤销要约的意思表示以对话方式作出的，该意思表示的内容应当在受要约 人作出承诺之前为受要约人所知道；撤销要约的意思表示以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人 2. 要约不得撤销 （1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销 （2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

（四）要约的失效

（1）要约被拒绝；

（2）要约依法被撤销；

（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。

（五）特殊要约

反要约	又称新要约，因承诺须与要约的内容一致方能成立合同，对要约修改后 所作“承诺”，实为一种新的要约，而非对要约的承诺
悬赏广告	1. 以广告的方式，对完成一定行为的人给予报酬的意思表示。是对不特定的人发出的要约 2. 相对人须以完成广告中指定的行为作承诺，方能成立合同 3. 我国民事法律规定，悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付
交叉要约	1. 又称交错要约，是指当事人双方互为意思内容相同的要约 2. 交叉要约中的两个意思表示，是相向发出的，且均在收到对方要约之前发出，可谓“不谋而合” ，故交叉要约互达于相对人时合同即成立
现物要约	1. 又称“无要约寄送” ，是指未经订购而当事人一方向相对人径寄物品的行为 2. 相对人不负有承诺义务，但在要约人领回物品前，有保管义务

二、承诺

承诺是受要约人同意要约的意思表示。

（一）构成要件

1. 承诺必须由受要约人向要约人作出。

2. 承诺的内容应当与要约的内容一致。

3. 承诺必须是在承诺期内到达要约人。

（二）承诺的迟到和延迟

承诺的迟到	1. 指承诺在承诺期限届满后才发出（承诺人的原因导致） 2. 原则上为新要约。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效
承诺的延迟	1. 指承诺人在承诺期限内发出承诺，但因承诺人以外的原因，导致本应在承诺期限内到达的承诺，在承诺期限届满后才到达要约人 2. 原则上该承诺有效。除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺
承诺撤回	承诺可以撤回；撤回的通知应当在承诺到达要约人前或者与承诺同时到达

	要约人

（三）合同成立的时间

1. 承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2. 当事人采用合同书形式订立合同的， 自当事人均签字、盖章或者按指印时合同 成立。在签字、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时， 该合同成立。

3. 法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

4. 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立

5. 当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的， 对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立，但是当事人另有约定的除外。

（四）合同成立的地点

1. 承诺生效的地点为合同成立的地点；

2. 采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；

3. 当事人采用合同书形式订立合同的，最后签名、盖章或者按指印的地点为合同 成立的地点，但是当事人另有约定的除外。

三、免责条款与格式条款

（一）免责条款

含义	是当事人事先以协议免除或者限制其将来责任的合同条款
免责条款无效情形	1. 造成对方人身伤害的 2. 因故意或者重大过失造成对方财产损失的

（二）格式条款

概念	格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款

格式条款无效	1. 提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的条款无效 2. 提供格式条款一方排除对方主要权利的条款无效 3. 违反法律强制性规定的格式条款无效
提示或者说明义务	1. 提供格式条款的一方应当采取合理的方式提示对方注意免除或减 轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，并按照对方的要求，对 该条款予以说明 2. 提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注 意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容
格式条款解释	1. 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释 2. 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一 方的解释 3. 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款

【考点9】合同的解除（★★）

约定解除	当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的 事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同
法定解除	1. 因不可抗力致使不能实现合同目的 2. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表 示不履行主要债务 3. 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 4. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同 目的 5. 法律规定的其他情形
解除权的行使	1. 通知解除：当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方 2. 诉讼或者仲裁解除：当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除

解除权的消灭	1. 法律规定或者当事人约定的解除权行使期限届满，当事人不行使 的，解除权消灭（除斥期间届满） 2. 法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，自解除权人 知道或者应当知道解除事由之日起 1 年内不行使的，解除权消灭 3. 法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，解除权消灭
裁判解除	裁判解除，是基于人民法院或者仲裁机构的裁判而发生的解除 1. 合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方 明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理 期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或 者解除合同。该条是关于“情事变更”规则的规定。“情事变更”， 作为“合同严守”的例外规则 2. “情事变更”，是指合同成立后，发生了当事人在缔约时无法预见且不可归责于当事人的重大变化，导致合同存在的基础动摇或丧失，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，该当事人可以请 求人民法院或者仲裁机构予以变更或者解除合同的制度求人民法院 或者仲裁机构变更或者解除合同 3. 合同成立后，因政策调整或者市场供求关系异常变动等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的涨跌，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，人民法院应当认定合同的基础条件发生了 “重大变化”

第十章 婚姻家庭与继承法 •

【考点1】离婚制度（★★★）

一、协议离婚

项目	内容
双方自愿	离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产及债务 处理等事项协商一致的意见
冷静期	1. 自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起 30 日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请 2. 在规定期间届满后 30 日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请

二、判决离婚

1. 人民法院审理离婚案件，应当进行调解，如感情确已破裂，调解无效，应准予 离婚。

2. 有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：

（1）重婚或者与他人同居；

（2）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；

（3）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；

（4）因感情不和分居满 2 年的。

3. 一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。

4. 经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满 1 年，一方再次提起离婚诉讼的， 应当准予离婚。

5. 现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一方有重大过错的除外。

6. 女方在怀孕期间，分娩后 1 年内或者终止妊娠后6 个月内，男方不得提出离婚； 但是，女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

三、离婚的法律后果

（一）离婚后的父母子女关系

1. 离婚后，不满 2 周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。

2. 已满 2 周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的 具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。

3. 父母与子女间的关系不因离婚而消除。

离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。

（二）共同财产处理

夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况， 按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。

1. 对夫或妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。

2. 夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚 时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。

具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

3. 共同债务处理离婚时，夫妻共同债务，应当共同偿还。

共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由法 院判决。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，夫或妻一方对外所负 的债务，相对人知道该约定的，以夫或者妻一方的个人财产清偿。

4. 离婚损害赔偿

有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

（1）重婚；

（2）与他人同居；

（3）实施家庭暴力；

（4）虐待、遗弃家庭成员；

（5）有其他重大过错。

【考点2】法定继承（★★★）

一、法定继承的适用范围

遗嘱继承优先于法定继承适用。在下列情况下，遗产中的有关部分按照法定继承 办理：

1. 遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的。

2. 遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权。

3. 遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止。

4. 遗嘱无效部分所涉及的遗产。

5. 遗嘱未处分的遗产。

二、法定继承人的继承顺序

（一）第一顺序的法定继承人

配偶、子女（婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女）、父母（生 父母、养父母和有扶养关系的继父母）、对公婆或岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳或女婿。

（二）第二顺序的法定继承人

兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

三、代位继承

（一）代位继承的条件

1. 代位继承人包括被继承人的子女的直系晚辈血亲或者被继承人的兄弟姐妹的子女（前提是该兄弟姐妹有继承权）。

2. 代位继承人作为第一顺序继承人参加继承，只能继承被代位人应继承的遗产份额。

3. 继承人丧失继承权的，其晚辈直系血亲不得代位继承。

（二）代位继承的规定

1. 被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。

2. 被继承人的孙子女、外孙子女、曾孙子女、外曾孙子女都可以代位继承，代位继承人不受辈数的限制。

3. 被继承人的养子女、 已形成扶养关系的继子女的生子女可以代位继承；被继承人亲生子女的养子女可以代位继承；被继承人养子女的养子女可以代位继承；与被继承人已形成扶养关系的继子女的养子女也可以代位继承。

4. 代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源，或者对被继承人尽过主要赡养义务的，分配遗产时，可以多分。

5. 丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母，无论其是否再婚，依照民法典规定作为第一顺序继承人时，不影响其子女代位继承。

四、转继承

1. 继承开始后，继承人于遗产分割前死亡，并没有放弃继承的，该继承人应当继 承的遗产转给其继承人，但是遗嘱另有安排的除外。

2. 转继承与代位继承的区别

项目	区别
性质不同	转继承发生两次继承
	代位继承只发生一次继承

发生时间和成立条件不同	转继承发生在继承开始后遗产分割前，并且任何一个继承人都可能 成为被转继承人
	代位继承的前提只能是被代位继承人先于被继承人死亡而发生
主体不同	转继承人是被转继承人死亡时生存的所有法定继承人，被转继承人 可以是被继承人的任一继承人
	代位继承中的代位继承人只能是被代位继承人的直系晚辈血亲，其 他法定继承人不能成为代位继承人
适用范围不同	转继承可以发生在法定继承中，也可以发生在遗嘱继承中
	代位继承只适用于法定继承，在遗嘱继承中不适用

五、应继份与酌情分得遗产

1. 同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。

2. 继承人协商同意的，也可以不均等。在下列情况下，同一顺序的法定继承人的份额可以不均等：

（1）对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。

（2）对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。

（3）有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

3. 非继承人酌情分得遗产的权利。

对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人，可以分给他们适当的遗产。

【考点3】遗嘱继承（★★★）

立遗嘱处分 个人财产	自然人可以依照民法典规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执 行人 【注】遗嘱是被继承人死后发生法律效力的单方民事法律行为

遗嘱继承	自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承 【注】 遗嘱继承的发生必须满足被继承人（遗嘱人）死亡和所立遗嘱合法这两个法律事实，缺少任何一项，遗嘱继承即不能发生（法定继承只需被继承人死亡即可发生）
遗赠	自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的 组织、个人（遗赠人必须是自然人，受遗赠人既可以是自然人，也可 以是法人，但必须是法定继承人范围以外的人） 【注】 遗赠是单方的民事法律行为（不需要受遗赠人同意即可发生法 律效力，但受遗赠人可以放弃受遗赠），该法律行为在遗赠人死亡时 发生法律效力（遗赠人作出遗赠未死亡之前，其可以随时依法定程序变更或撤销自己的意思表示）。遗赠是给予法定继承人以外的人财产 利益的民事法律行为（法律不允许遗嘱人通过单方民事法律行为给受遗赠人带来不利）
遗嘱信托	自然人可以依法设立遗嘱信托

• 第十一章 个人独资企业法 •

【考点1】个人独资企业的特征(★★)

一、个人独资企业的特征

项目	内容
“人”	1. 出资人只能是一个自然人（中国公民）
“财”	2. 投资人对企业债务承担无限责任（先企业后个人）
“名、责”	3. 不能独立的承担民事责任：个人独资企业不具有法人资格
	4. 能独立从事民事活动

【考点2】个人独资企业的设立、变更、解散和清算(★★)

一、设立

设立的条件	1. 投资人为一个自然人。即使以家庭财产投资的，也只能以一个自然 人的名义投资 2. 有合法的企业名称 3. 有投资人申报的出资 （1）个人独资企业投资人必须有出资 （2）出资数额由投资人申报 （3）资金来源未作限定 （4）出资形式未作限定 4. 有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件 5. 有必要的从业人员
成立日期	营业执照的签发日期为个人独资企业成立日期
设立程序	1. 提出申请 2. 市场主体登记

二、变更

登记	个人独资企业人续存期间登记事项发生变更的，应当办理变更登记
提交文件	1. 投资人签署的变更登记申请书 2. 国家市场监督管理总局规定提交的其他文件
执照更换	1. 登记机关应当在收到投资人所提交且符合法律规定的全部文件，符 合条件予以核准的，换发《营业执照》 2. 对不符合《个人独资企业法》规定条件的变更登记申请，做出不予 登记的决定

三、解散和清算

应当解散的情形	1. 投资人决定解散 2. 投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继承 3. 被依法吊销营业执照 4. 法律、行政法规规定的其他情形
解散程序	1. 由投资人自行清算或由债权人申请法院指定清算人进行清算 2. 投资人自行清算的，应当在清算前 15 日内书面通知债权人，无法通知的，应当予以公告。债权人接到通知之日起 30 日内，未接到通知的在公 告之日起 60 日内，向投资人申报其债权 3. 个人独资企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在 5 年内未向债务人提出偿债请求的，该责任消灭
清偿顺序	1. 所欠职工工资和社会保险费用 2. 所欠税款 3. 其他债务 个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产 予以清偿。个人独资企业清算结束后，投资人或者法院指定的清算人应 当编制清算报告，并于 15 日内到登记机关办理注销登记

【考点3】个人独资企业的事务管理(★★)

一、管理方式

投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人 负责企业的事务管理。

二、投资人的内部限制

个人独资企业的投资人对受托人或者被聘用的人员的限制，不得对抗善意第三人。

即受托人或者被聘用的人员超出投资人的限制与善意第三人的有关业务交往应当 有效（该限制对外无效，对内有效）。

三、对受托人的法定限制

1. 不得利用职务上的便利，索取或者收受贿赂。
2. 不得利用职务或者工作上的便利侵占企业财产。
3. 不得挪用企业的资金归个人使用或者借贷给他人。

4. 不得擅自将企业资金以个人名义或者以他人名义开立账户储存。

5. 不得擅自以企业财产提供担保。

6. 未经投资人同意，不得从事与本企业相竞争的业务。

7. 未经投资人同意，不得同本企业订立合同或者进行交易。

8. 未经投资人同意，不得擅自将企业商标或者其他知识产权转让给他人使用。

9. 不得泄露本企业的商业秘密。

10. 法律、行政法规禁止的其他行为。

第十二章 合伙企业法

【考点1】合伙企业的财产（★★）

一、合伙企业财产的构成

合伙企业的财产包括合伙人的出资（原始财产）、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产（积累财产）。

合伙企业财产独立于合伙人的个人财产，合伙人不能直接支配合伙企业财产。

合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。但是，《合伙企业法》另有规定的除外。

二、财产份额的处分

合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的，合伙企业不得对抗善意第三人。

三、合伙人的财产份额

项目		普通合伙人	有限合伙人
转让	对内	合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人	
	对外	除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意（在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是，合伙协议另有	有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前 30 日通知其他合伙人（有限合伙企业的其他合伙人有

		约定的除外）	优先购买权）
出质		合伙人以其在合伙企业中的财产份 额出质的，须经其他合伙人一致同意（合伙协议不得另有约定）	有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质；但是，合伙协议另有约定的除外

【考点2】合伙企业事务执行(★★)

执行方式	1. 全体合伙人共同执行，享有同等的权利 2. 按合伙协议约定或经全体合伙人决定，可以委托一个或数个合伙人对 外代表合伙企业，执行合伙事务，其他合伙人不再执行 【注】 作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表 执行

权利	1. 普通合伙人在合伙企业中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督 权和代表权 2. 执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业 3. 不执行合伙事务的合伙人的监督权利 4.（所有）合伙人查阅企业会计账簿等财务资料的权利 5. 合伙人有提出异议的权利和撤销委托的权利

【考点3】有限合伙企业(★★)

一、有限合伙企业的设立

	人数	2 个以上 50 个以下合伙人设立，法律另有规定除外
	组成	有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人 【注】有限合伙企业仅剩有限合伙人，应当解散；有限合伙企业仅剩

合伙人		普通合伙人，应当转为普通合伙企业
	资格	自然人、法人和其他组织可以设立有限合伙企业 【注】国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人，可以成为有限合伙人
出资	出资期限	有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任
	出资形式	有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资，不得以劳务出资
名称	有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样	

二、有限合伙企业的自己交易、竞业、出质与转让

	有限合伙人	普通合伙人
关联交易	可以同本企业进行交易；有约定的除外（先约定，无约定可以）	不得同本企业进行交易，有约定或全体合伙人一致同意除外（先约定或同意，否则不得）
竞业禁止	可以自营或同他人合作经营与本企业相竞争的义务；有约定除外（先约定，无约定可以）	不得自营或同他人合作经营与本企业相竞争的业务（绝对禁止）
出质	可以将其财产份额出质；约定的除外（先约定，无约定可以）	财产份额出质，须经其他合伙人一致同意（必须一致同意）
对外转让	可以向外人转让其财产份额，应提前30日通知其他合伙人，其他合伙人有优先购买权（对外转让需通知）	除另有约定外，向外人转让财产份额，须经其他合伙人一致同意，其他合伙人有优先购买权（对外转让需一致同意）
	【注】两类合伙人对内转让其财产份额，应当通知其他合伙人	

【考点4】入伙与退伙（★★★）

一、入伙

1. 新合伙人入伙，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法 订立书面入伙协议。

2. 订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和 财务状况。

3. 入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙协议另有约定 的，从其约定。新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

二、退伙

（一）协议退伙

情形	1. 合伙协议约定的退伙事由出现 2. 经全体合伙人一致同意 3. 发生合伙人难以继续参加合伙的事由；如因犯罪被判刑，患有严重的疾病等 4. 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务

（二）声明退伙

1. 声明退伙是合伙人基于自己的意愿而表示退伙

2. 声明退伙应当有正当的理由，否则被视为违法退伙

3. 合伙人违法退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

（三）法定退伙（当然退伙）

1. 合伙人有下列情形之一的，当然退伙：

（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；

（2）个人丧失偿债能力；

（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销， 或者被宣告破产；

（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；

（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

2. 合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合 伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。其 他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人退伙。

3. 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

（四）除名退伙

1. 合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

（1）未履行出资义务；

（2）因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；

（3）执行合伙事务时有不正当行为；

（4）发生合伙协议约定的事由。

【考点5】合伙企业解散、清算（★★）

一、合伙企业的解散

含义	解散是指合伙企业因某种法律事实的发生而使其民事主体资格归于消灭 的法律行为
解散事由	1. 合伙期限届满，合伙人决定不再经营 2. 合伙协议约定的解散事由出现 3. 全体合伙人决定解散 4. 合伙人已不具备法定人数满 30 日 5. 合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现 6. 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销 7. 法律、行政法规规定的其他原因

二、清算

清算人	1. 由全体合伙人担任 2. 经全体合伙人过半数同意，可自解散事由出现后 15 日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人 3. 自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定的，合伙人或者其他利

	害关系人可申请法院指定清算人	
通知	清算人	自被确定之日起 10 日内通知债权人，并于60 日内在报纸上公告
	债权人	接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，向清算人申报债权
财产支付顺序	1. 支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金 2. 缴纳所欠税款 3. 清偿债务 4. 剩余财产，依照《合伙企业法》的有关规定进行分配	
注销后的责任承担	企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连 带责任	

第十三章 公司法

【考点1】公司章程(★★)

定义	公司章程是公司依法制定的规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件，是公司组织和活动的基本准则，常被称作“公司的宪法”	
效力	由股东或发起人共同制定，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力	
订立方式	共同订立	由全体股东或发起人共同起草、协商制定公司章程，否则公司章程不得生效
	部分订立	由股东或发起人中的部分成员负责起草、制定公司章程，再经其他股东或发起人签字同意
	有限责任公司章程由股东共同制定，并在公司章程上签名或者盖章	
	采取发起方式设立的，章程由发起人共同制定；采取募集方式设立的股份有限公司，章程须经公司成立大会通过	
	国有独资公司章程由履行出资人职责的机构制定	

载明事项	有限责任公司	1. 公司名称和住所；2. 公司经营范围；3. 公司注册资本；4. 股东的姓名或者名称；5.股东的出资额、出资方式和出资日期；6.公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；7. 公司法定代表人 的产生、变更办法；8. 股东会认为需要规定的其他事项
	股份有限公司	1. 公司名称和住所；2. 公司经营范围；3. 公司设立方式；4. 公司注册资本、已发行的股份数和设立时发行的股份数，面额股 的每股金额；5. 发行类别股的，每一类别股的股份数及其权利 和义务；6. 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式；7. 董事会的组成、职权和议事规则；8. 公司法定代表人的产生、变更办法；9. 监事会的组成、职权和议事规则； 10. 公司利润分配办法；11 公司的解散事由与清算办法；12. 公司的通知和 公告办法；13. 股东会认为需要规定的其他事项
	发行类别股的公司	1. 类别股分配利润或者剩余财产的顺序；2. 类别股的表决权数；3. 类别股的转让限制；4. 保护中小股东权益的措施；5. 股东会认为需要规定的其他事项
	上市公司的公司章程除执行股份有限公司章程应当载明事项的规定外，还应当依照法律、行政法规的规定载明董事会专门委员会的组成、职权以及董事、 监事、高级管理人员薪酬考核机制等事项	
效力	公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力	
	公司章程作为公司的内部规章，效力仅及于公司和相关当事人，不具有普遍约束力	

	修改程序	修改公司章程属于股东会职权，由股东会表决通过
		有限责任公司股东会会议作出修改公司章程的决议，应当经代表 2/3 以上表决权的股东通过
		股份有限公司股东大会作出修改公司章程的决议，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过
		公司章程变更涉及公司登记事项的，公司应当向原公司登记机关申

变更	变更登记	请变更登记
		公司章程修改未涉及登记事项的，公司应当将修改后的公司章程或者公司章程修正案送原公司登记机关备案
		公司章程中有关股东出资额或者发起人认购股份、出资时间及方式的规定发生变化的，应当向公司登记机关依法申请办理公司章程或者公司章程修正案备案

【考点2】公司登记（★★）

设立登记	1. 设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，应当在公司登记前依法办理批准手续 2. 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期	
变更登记	公司登记事项发生变更的，应当依法办理变更登记。公司登记事项未经登记或者未经变更登记，不得对抗善意相对人	
注销登记	简易注销	1. 公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东 承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。股东对规定的内容 承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任 2. 通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统 予以公告，公告期限不少于 20 日。公告期限届满后，未有异议的，公 司可以在 2 0 日内向公司登记机关申请注销公司登记
	强制注销	1. 公司被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，满 3 年未向公司登记 机关申请注销公司登记的，公司登记机关可以通过国家企业信用信息 公示系统予以公告，公告期限不少于 60 日 2. 公告期限届满后，未有异议的，公司登记机关可以注销公司登记， 原公司股东、清算义务人的责任不受影响

【考点3】公司法人（★★）

一、公司的独立法人资格

定义	公司的独立法人资格，即公司的独立主体资格，来源于法律赋权和确认，并独立于它的股东和成员。公司是否拥有独立的财产，能否以自己名义独立承担责任，是判断公司是否具有独立法人资格的标志

公司法人财产制度	企业法人财产独立于股东而存在，股东一经对公司出资或者购买公司 股份，股东财产就转变为公司财产，为公司所有
股东有限责任制度	股东仅以其认缴的出资额或购买的股份为限对公司承担责任，公司以其拥有的全部财产为限对自己的债务承担责任，公司债权人不可向股东追及

二、公司法人人格否认制度

概念	又称揭开公司面纱，是指为防止法人独立人格的滥用和保护公司债权 人的利益，在承认公司具有法人人格的前提下，在特定的法律关系中 对公司人格及股东有限责任加以否定，以规制股东滥用公司人格及有 限责任，保护公司债权人及社会公共利益的一项法律制度。公司法人 人格否认意味着股东或关联公司将对公司债务承担连带责任
法律依据	1. 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任 2. 只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任
构成要件	1. 行为主体必须是股东或者关联公司 2. 行为人必须有逃避债务的行为，逃避债务的行为必须是通过滥用公司法人独立地位和股东有限责任的方式实现的 3. 滥用公司法人人格的行为对债权人利益造成了严重损害，具体表现为公司财产不足以清偿债权人债务

人格混同的认定	在认定是否构成人格混同时，应当综合考虑以下因素： 1. 股东无偿使用公司资金或者财产，不作财务记载的 2. 股东用公司的资金偿还股东的债务，或者将公司的资金供关联公司无偿使用，不作财务记载的 3. 公司账簿与股东账簿不分，致使公司财产与股东财产无法区分的 4. 股东自身收益与公司盈利不加区分，致使双方利益不清的 5. 公司的财产记载于股东名下，由股东占有、使用的 6. 人格混同的其他情形
过度支配与控制的认定	实践中常见的情形包括： 1. 母子公司之间或者子公司之间进行利益输送的 2. 母子公司或者子公司之间进行交易，收益归一方，损失却由另一方承担的 3. 先从原公司抽走资金，然后再成立经营目的相同或者类似的公司，逃避原公司债务的 4. 先解散公司，再以原公司场所、设备、人员及相同或者相似的经营 目的另设公司，逃避原公司债务的 5. 过度支配与控制的其他情形

【考点4】股东出资（★★）

一、出资方式

项目	内容
一般规定	股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外
出资手续	1. 股东以货币出资的：足额存入公司在银行开设的账户 2. 以非货币财产出资的，应当依法办理财产权的转移手续

股权不得用于出资情形	1. 已被设立质权 2. 股权所在公司章程约定不得转让 3. 法律、行政法规或者国务院决定规定，股权所在公司股东转让股权应当报经批准而未经批准 4. 法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形
债转股应符合的情形	1. 债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或公司章程的禁止性规定 2. 经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认 3. 公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议

二、出资责任

（一）股东、出资人赔偿责任

股东或者出资人未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

（二）连带责任

1. 公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资或者发起人不按照其认购的股份缴纳股款，股东实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额或者发起人作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的；

设立时的其他股东、其他发起人与该股东、该发起人在出资不足的范围内承担连带责任。

2. 抽逃出资的形态：

（1）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；

（2）通过虚构债权债务关系将其出资转出；

（3）利用关联交易将出资转出；

（4）其他未经法定程序将出资抽回的行为。

3. 抽逃出资的民事责任

股东或者出资人抽逃出资的，股东或者出资人应当返还抽逃的出资；给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当与该股东或者该出资人承担连带赔偿责任。

三、股东失权制度

（一）董事的赔偿责任

公司成立后，董事会应当对股东或者出资人的出资情况进行核查，发现股东或者出资人未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东或者出资人发出书面催缴书，催缴出资。未及时履行规定义务给公司造成损失的，负有责任的董事应当承担赔偿责任。

（二）失权宽限期

发出书面催缴书催缴出资的，可以载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司发出催缴书之日起，不得少于 60 日。

（三）股东失权程序

宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知，通知应当以书面形式发出。自通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资的股权。

丧失的股权应当依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权；6 个月内未转让或者注销的，由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资。

（四）股东失权救济

股东对失权有异议的，应当自接到失权通知之日起 30 日内，向人民法院提起诉讼。

四、出资加速到期制度

【考点5】股东诉讼(★★)

一、股东代表诉讼

股东资格	有限责任公司	股东
	股份有限公司	连续 >180 日 + 单独或者合计 >1% 股份的股东
穷尽公司内部救济（交叉请求规则）	董、高：监事会	董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，符合条件的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼
	监：董事会	监事执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，符合条件的股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼

股东代表诉讼情形	1. 收到规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 2. 自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼 3. 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害
	符合条件的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼
他人侵犯公司权益	他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，符合条件的股东可以依照规定向人民法院提起诉讼
股东双重代表诉讼	公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，符合条件的股东可以依照规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼

二、股东直接诉讼

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的， 股东可以向人民法院提起诉讼。

【注】 股东代表诉讼的提起是为了维护公司利益，而股东直接诉讼则是为了股东 自己的利益。

三、解散公司诉讼

主体	持有公司 10% 以上表决权的股东
情形	公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决，提起解散公司诉讼，人民法院应予受理： 1. 公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的 2. 股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续 2 年以上不能作出有效的股东会决议，公司经营管理发生严重困难的 3. 公司董事长期冲突，且无法通过股东会解决，公司经营管理发生严重困难的 4. 经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形

不予受理	股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害、或者公司亏损、对产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销企业法人营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不子受理

第十四章 破产法

【考点1】破产原因（★★★）

一、判断标准

不能清偿到期债务	指债务人已全面停止偿付到期债务而且没有充足的现金流偿付正常 营业过程中到期的现有债务
	认定不能清偿到期债务应同时具备三个方面的条件： 1. 债权债务关系依法成立 2. 债务履行期限已经届满 3. 债务人未完全清偿债务，即债务人未清偿债务的状态客观存在。不论债务人的客观经济状况如何，只要其没有完全清偿到期债务的， 均构成不能清偿到期债务
资产不足以清 偿全部债务	1. 债务人的资产负债表，或者审计报告、资产评估报告等显示其全部资产不足以偿付全部负债的，人民法院应当认定债务人资产不足 以清偿全部债务，但有相反证据足以证明债务人资产能够偿付全部 负债的除外 2. 计算债务数额时，不考虑是否到期，均纳入总额之内
明显缺乏清偿能力	债务人账面资产虽大于负债，但存在下列情形之一的，人民法院应当认定其明显缺乏清偿能力： 1. 因资金严重不足或者财产不能变现等原因，无法清偿债务 2. 法定代表人下落不明且无其他人员负责管理财产，无法清偿债务 3. 经人民法院强制执行，无法清偿债务 4. 长期亏损且经营扭亏困难，无法清偿债务 5. 导致债务人丧失清偿能力的其他情形

二、破产分类

申请人	破产原因	适用情况

债务人申请	债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务	1. 债务人自己提出破产申请 2. 资不抵债状况通过形式审查即可判断的案件
债权人申请	债务人不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力	1. 债权人提出破产申请 2. 债务人提出破产申请但其资不抵债状况通过形式审查不易判断的案件

【考点2】破产案件的申请（★★★）

申请人	申请条件	申请种类
债务人	债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力	提出重整、和解或者破产清算申请
债权人	债务人不能清偿到期债务	提出重整或破产申请
清算人	企业法人已解散但未清算或未清算完毕，资产不足以清偿债务	申请破产清算
国务院金融监督管理机构	商业银行、证券公司、保险公司等金融机构具有破产原因	重整或破产清算

【注】在债务人被人民法院破产宣告前，上述申请人的申请内容和程序可以转换：

债权人申请债务人清算	债务人可以申请和解	债务人或其出资人可以申请重整
债务人申请清算的	债权人或债务人的出资人可以申请重整	债务人也可以申请和解
债务人进入重整或和解程序	失败时，经破产宣告转入清算程序	
债务人一旦经破产宣告进入清算程序		则不得转为重整或和解

【考点3】债权申报（★★★）

一、破产债权与破产债权申报

破产债权	破产申请受理前成立，经依法申报确认，通过破产程序从破产财产中获得公平清偿，可强制执行的财产请求权
破产债权的申报	1. 指债权人在法院受理破产申请后依照法定程序和期限，主张并证明其债权存在，参加破产程序的法律行为 2. 债权申报是债权人参加破产程序，行使权利的基础
申报的期限	自法院发布受理破产申请公告之日起算，最短不得少于 30 日，最长不超过 3 个月

二、可以申报债权的情形

1. 未到期债权破产申请受理时视为到期。附利息债权， 自破产申请受理时起停止计息。

2. 附条件、附期限债权和诉讼、仲裁未决的债权。

3. 连带债权人可以由其中一人代表全体连带债权人申报债权，也可以共同申报债权。

4. 债务人的保证人或者其他连带债务人已经代替债务人清偿债务的，以其对债务人的求偿权申报债权。尚未代替债务人清偿债务的，以其对债务人的将来求偿权申报债权。但是，债权人已经向管理人申报全部债权的除外。

5. 保证人被裁定进入破产程序的，债权人有权申报其对保证人的保证债权。主债务未到期的，保证债权在保证人破产申请受理时视为到期。一般保证的不能主张行使 先诉抗辩权，但债权人在一般保证人破产程序中的分配额应予提存，待一般保证人应 承担的保证责任确定后再按照破产清偿比例予以分配。

保证人被确定应当承担保证责任的，保证人的管理人可以就保证人实际承担的清偿额向主债务人或其他债务人行使求偿权。

6. 债务人、保证人均被裁定进入破产程序的，债权人有权向债务人、保证人分别申报债权。债权人向债务人、保证人均申报全部债权的，从一方破产程序中获得清偿后，其对另一方的债权额不作调整，但债权人的受偿额不得超出其债权总额。保证人履行保证责任后不再享有求偿权。

7. 连带债务人数人被裁定适用破产程序的，其债权人有权就其全部债权分别在各破产案件中申报债权。

8. 管理人或者债务人依照破产法规定解除合同的，对方当事人以因合同解除所产生的损害赔偿请求权申报债权。

9. 债务人是委托合同的委托人，被裁定适用破产法规定的程序，受托人不知该事实，继续处理委托事务的，受托人以由此产生的请求权申报债权。

10. 债务人是票据的出票人，被裁定适用法律规定的程序，该票据的付款人继续付款或者承兑的，付款人以由此产生的请求权申报债权。

11. 法院裁定受理破产申请前债务人尚未支付的案件受理费、执行申请费，可以作为破产债权申报。但破产申请受理后，债务人欠缴款项产生的滞纳金，包括债务人未履行生效法律文书应当加倍支付的迟延利息和劳动保险金的滞纳金，债权人不能作为破产债权申报。

12. 职工劳动债权不必申报。债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，应划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。

三、债权登记与确认

（一）债权登记

1. 管理人收到债权申报材料后，应当进行登记造册。

2. 管理人应当对申报的债权性质、数额、担保财产、是否超过诉讼时效期间、是否超过强制执行期间等情况进行审查，编制债权表并提交第一次债权人会议核查。

3. 债权表、债权申报登记册及债权申报资料在破产期间由管理人保存，债权人、债务人、债务人职工及其他利害关系人有权查阅。

（二）债权确认

1. 债务人、债权人对债权表记载的债权无异议的，由法院裁定确认。

债务人、债权人对债权表记载的债权有异议的，应当说明理由和法律依据。经管理人解释或调整后，异议人仍然不服的，或者管理人不予解释或调整的，异议人应当

在债权人会议核查结束后 15 日内向法院提起债权确认的诉讼。有仲裁条款或仲裁协议的，应当向选定的仲裁机构申请确认债权债务关系。

2. 已经生效法律文书确定的债权，管理人应当予以确认。

管理人有异议的，应当依法通过审判监督程序向法院申请撤销生效法律文书，申请撤销或者不予执行仲裁裁决、不予执行公证债权文书后，重新确定债权。

【考点4】破产费用和共益债务（★★★）

一、破产费用

破产费用是指为全体债权人的共同利益，在破产程序进行中支出，从债务人财产 中拨付的费用。破产费用包括：

1. 破产案件的诉讼费用。

2. 管理、变价和分配债务人财产的费用。

3. 管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。

4. 人民法院裁定受理破产申请的，此前债务人尚未支付的公司强制清算费用、未终结的执行程序中产生的评估费、公告费、保管费等执行费用，可以参照破产法关于 破产费用的规定，由债务人财产随时清偿。

【注】此前债务人尚未支付的案件受理费、执行申请费， 可以作为破产债权清偿。

二、共益债务

共益债务是指人民法院受理破产申请后，为了全体债权人的共同利益以及破产程序顺利进行而发生的应由债务人财产负担的债务总称。包括：

1. 因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务。
2. 债务人财产受无因管理所产生的债务。
3. 因债务人不当得利所产生的债务。
4. 为债务人继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务。
5. 管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务。
6. 债务人财产致人损害所产生的债务。

三、清偿原则

1. 破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。
2. 债务人财产不足以清偿所有破产费用和共益债务的，先行清偿“破产费用”。
3. 债务人财产不足以清偿所有破产费用或者共益债务的，按照“比例清偿”。
4. 如果债务人财产不足以支付破产费用的，管理人应当提请人民法院终结破产程序。

【注】 债务人财产不足以支付所有破产费用，但破产案件的债权人、管理人、债务人的出资人或者其他利害关系人愿意垫付相关费用的，经人民法院同意，破产程序 可以继续进行。

【考点5】抵销权（★★★）

提出主体	债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销 【注】 管理人不得主动抵销债务人与债权人的互负债务，但抵销使债务人财产受益的除外
抵销生效	1. 管理人无异议：抵销自管理人收到通知之日起生效 2. 管理人有异议：法院判决驳回管理人提起的抵销无效诉讼请求的， 该抵销自管理人收到主张债务抵销的通知之日起生效

异议	管理人异议的，应当在约定的异议期限内或者自收到主张债务抵销的通知之日起 3 个月内向法院提起诉讼。无正当理由逾期提起的，法院不予支持
	管理人下列异议，法院不支持： 1. 破产申请受理时，债务人对债权人负有的债务尚未到期 2. 破产申请受理时，债权人对债务人负有的债务尚未到期 3. 双方互负债务标的物种类、品质不同
不得抵销	1. 债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的 2. 债权人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人负担债务的；但是，债权人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而负担债务的除外 3. 债务人的债务人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人取得债权的；但是，债务人的债务人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而取得债权的除外
抵销无效	破产申请受理前 6 个月内，债务人具有破产原因，债务人与个别债权人以抵销方式对个别债权人清偿，其抵销的债权债务属于上述（不得抵销）第 2、3 项规定的情形之一，管理人在破产申请受理之日起 3 个月内向法院提起诉讼，主张该抵销无效的，法院应予支持
股东抵销限制	债务人的股东主张以下列债务与债务人对其负有的债务抵销，债务人 管理人提出异议的，法院应予支持： 1. 债务人股东因欠缴债务人的出资或者抽逃出资对债务人所负的债务 2. 债务人股东滥用股东权利或者关联关系损害公司利益对债务人所负的 债务

第十五章 电子商务法

【考点1】电子商务合同（★★★）

<table>
<tr><td>民事行为能力</td><td colspan="2">在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力，但有相反证据足以推翻的除外</td></tr>
<tr><td>合同成立</td><td colspan="2">电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立
【注】不得以格式条款约定消费者支付价款后合同不成立</td></tr>
<tr><td rowspan="5">数据电文发送与接收</td><td>视为发件人发送</td><td>1. 经发件人授权发送的
2. 发件人的信息系统自动发送的
3. 收件人按照发件人认可的方法对数据电文进行验证后结果相符的
【注】另有约定，从其约定</td></tr>
<tr><td>视为收到</td><td>发件人收到收件人的收讫确认时，视为已经收到</td></tr>
<tr><td rowspan="2">有约定按约定，未约定按以下规定</td><td>【发送时间】数据电文进入发件人控制之外的某个信息系统的时间，视为发送时间</td></tr>
<tr><td>【接收时间】
1. 收件人指定特定系统接收数据电文的，数据电文进入该特定系统的时间，视为接收时间
2. 未指定特定系统的，数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为接收时间</td></tr>
<tr><td rowspan="2">有约定按约定，未约定按以下规定</td><td>【发送地点】发件人的主营业地为数据电文的发送地点；没有主营业地的，其经常居住地为发送地点</td></tr>
<tr><td>【接收地点】收件人的主营业地为数据电文的接收地点；没有主营业地的，其经常居住地为接收地点</td></tr>
</table>

	交付时间有约定按约定，未约按以下规定	1. 合同标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人签收时间为交付时间 2. 合同标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为交付时间；前述凭证没有载明或载明时间与实际提供服务时间不一致，实际提供服务的时间为交付时间 3. 合同标的为采用在线传输方式交付的，合同标的进入对方当事人指定的特定系统并且能够检索识别的时间为交付时间
自动信息系统	1. 电子商务当事人使用自动信息系统订立或者履行合同的行为对使用该系统的当事人具有法律效力 2. 因技术故障，未按照预先设定的程序指令、算法、参数与条件运行，导致数据电文未按时传递、传递不完整或者失实， 使用自动信息系统的一方当事人应当承担相应的法律后果；给对方当事人造成损失的，应当赔偿 3. 自动信息系统的使用者可以向开发者、提供者追偿	

【考点2】电子签名（★★★）

项目	具体规定
特征	1. 电子签名是以电子形式出现的数据 2. 电子签名是附着于数据电文的 3. 电子签名须能识别签名人身份并表明签名人认可与电子签名相联系 的数据电文的内容
形式	电子签名形式多样，如电子化签名、密码签名、生物特征签名、数字签 名等

法律效力	1.在排除三种特殊情况（包括涉及婚姻、收养、继承等人身关系；停止供水、 供热、供气等公用事业服务以及法律行政法规规定的不适用电子文书的其他情形等）的前提下，全面认可了民商事活动中产生的各类电子签名、 数据电文的法律效力 2. 当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，不得仅因为其采用电子 签名、数据电文的形式而否定其法律效力 3. 能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符 合法律、法规要求的书面形式 4. 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力 5. 可靠的电子签名应具备的条件 （1）电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有 （2）签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制 （3）签署后对电子签名的任何改动能够被发现 （4）签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现 6. 电子签名人的法律义务 （1）应当妥善保管电子签名制作数据 （2）电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密时， 应当及时告知有关各方，并终止使用该电子签名制作数据

十六章 社会保险法

【考点1】基本养老保险（★★）

一、职工基本养老保险

（一）基本养老保险适用范围

适用于各类企业及其职工、事业单位及其工作人员、灵活就业人员、中国境内就 业的外国人。

（二）基本养老保险基金的组成

1. 用人单位和个人缴费。

2. 基本养老保险费利息和其他收益。

3. 财政补贴。

4. 滞纳金。

5. 其他资金。如养老基金投资运营的收益。

（三）个人账户资金

设立个人账户资金就是强制个人储蓄，由国家强制提取。个人缴纳的基本养老保险费计入个人账户，退休之前个人不得提前支取。

（四）职工基本养老保险待遇的给付

1. 给付条件：

（1）达到国家规定的退休年龄并办理相关手续；

（2）基本养老保险费累计缴费年限满 15 年。

2. 丧葬补助金和抚恤金：

参加职工基本养老保险的个人，因病或非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。

3. 病残津贴：参保人未达到法定退休年龄时“因病或非因工致残完全丧失劳动能力”的，可以领取病残津贴。

【注】所需资金从基本养老保险基金中支付。

（五）基本养老保险关系的转移与接续

个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

二、公务员和参公管理工作人员养老保险

公务员和参公管理工作人员养老保险适用对象有：

1. 公务员；

2. 参照《公务员法》管理的工作人员。

三、新型农村社会养老保险

（一）新型农村社会养老保险的筹资方式

1. 个人缴费。

2. 集体补助。

3. 政府补贴。

（二）新型农村社会养老保险的待遇条件

1. 参保对象是年满 16 周岁（不含在校生）、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民，他们可以在户籍地自愿参加新型农村社会养老保险。

2. 参加新型农村社会养老保险的农村居民，符合国家规定条件的，按月领取新型农村社会养老保险待遇。

四、城镇居民社会养老保险

（一）参保对象

年满 16 周岁（不含在校学生）、不符合职工基本养老保险参保条件的城镇非从业居民，可以在户籍地自愿参加城镇居民养老保险。

（二）城镇居民养老保险基金组成

城镇居民养老保险基金主要由个人缴费和政府补贴构成。

【考点2】工伤保险(★★)

参保对象	中国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（不包括公务员、参照《公务员法》管理的工作人员）
缴纳主体	由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费
工伤认定	1. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 2. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 3. 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 4. 患职业病的 5. 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 6. 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的 7. 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形
视同工伤	1. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的 2. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

	3. 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证， 到用人单位后旧伤复发的

不得认定	1. 因故意犯罪受到伤害的 2. 因醉酒或者吸毒受到伤害的 3. 自残或者自杀的 4. 法律、行政法规规定的其他情形
申请	用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 1 年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请
举证责任	职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的， 由用人单位承担举证责任
工伤保险待遇	工伤保险基金负担：工伤医疗康复待遇、辅助器具配置待遇、伤残待遇、死亡待遇
工伤保险基金	用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金

【考点3】医疗保险(★★)

城镇职工基本医疗	参保范围	应当	职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费
		可以	无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费
		被保险人在自然生病时享受基本的医疗服务	
		符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付	

保险	适用范围	下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围： 1. 应当从工伤保险基金中支付的 2. 应当由第三人负担的 3. 应当由公共卫生负担的 4. 在境外就医的
新型农村合作医疗	覆盖全体农村居民，所有农村居民都可以家庭为单位自愿参加，一般采取以县（市）为单位进行统筹	
城镇居民医疗保险	不属于城镇职工基本医疗保险制度覆盖范围的中小学阶段的学生（包括职业高中、中专、技校学生）、少年儿童和其他非从业城镇居民可自愿参加城镇居民基本医疗保险	

第十七章 民事诉讼法

【考点1】民事诉讼管辖（★★★）

一、级别管辖

最高院	全国范围内有重大影响的一审案件 + 认为应由自己审理的案件
高院	本辖区内有重大影响的一审民事案件
中院	1. 重大涉外案件（包括争议标的额大的案件、案情复杂的案件，或一方当事人人数众多等具有重大影响的案件） 2. 在本辖区有重大影响的案件 3. 最高法院确定由中级法院管辖的案件
基层	剩下的

【注】专利纠纷案件由知识产权法院、最高法院确定的中级法院和基层法院管辖。 海事、海商案件由海事法院管辖。

二、地域管辖

	概念：是指以当事人的住所地与法院辖区的隶属关系来确定的管辖

一般地域管辖	公民：被告住所地法院管辖；住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地法院管辖 【注】 被告经常居住地（连续居住 1 年以上）＞被告住所地（户籍所在地） 法人或组织：被告主要办事机构所在地
特殊地域管辖	指以当事人住所地、诉讼标的、诉讼标的物所在地，或者引起法律关系发生、变更或者消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖
协议管辖（书面协议）	概念：指当事人在争议发生之前或者发生之后，用书面协议的方式，选择管辖法院
	适用范围：合同或其他财产权益纠纷的当事人
	选择范围：被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的法院管辖
	限制：不得违反级别管辖和专属管辖的规定

专属管辖 （不准当事人 协议变更）	概念：指基于法律规定，某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，也不准许当事人协议变更管辖
	1. 因不动产纠纷提起的诉讼：不动产所在地 2. 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼：港口所在地 3. 因继承遗产纠纷提起的诉讼：由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地
共同管辖、选择管辖	1. 两个以上人民法院都有管辖权的诉讼（共同管辖），原告可以向其中一个人民法院起诉（选择管辖） 2. 原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖 3. 人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案；立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，裁定将案件移送给先立案的人民法院。先立案的人民法院不得将案件 移送给另一个有管辖权的人民法院

指定管辖	1. 有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级 人民法院指定管辖 2. 人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解 决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。
移送管辖	移送管辖是指法院受理案件后发现无管辖权时，将案件移送给有管 辖权的法院审理

【考点2】必要共同诉讼与普通共同诉讼比较(★★★)

	必要共同诉讼	普通共同诉讼
当事人人数	当事人一方或双方为 2 人以上	
诉讼标的	共同的（1 个）	同一种类（多个）
是否可分	不可分，必须合并审理	可分，不一定合并审理
裁判	必须同一裁判	应当分别裁判
诉讼人之间关系	共同诉讼人必须一同起诉或者一 同应诉，彼此有连带关系，其中 1 人的行为经其他共同诉讼人承 认，对其他共同诉讼人发生效力	普通的共同诉讼人之间没有共同的权利义务，其中 1 人的行为，对其他共同诉讼人不发生效力
管辖法院	只有一个诉讼，按规定法院管辖	几个诉讼必须属于同一 法院管辖、适用同一种诉讼程序

【考点3】民事诉讼证明对象(★★★)

须证明的对象	无须证明的事实
1. 当事人主张的民事实体权益所根据的事实。（如借钱的事实）	1. 自然规律以及定理、定律 2. 众所周知的事实 3. 根据法律规定推定的事实 4. 根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实

2. 当事人主张的具有程序性质的法律事实。（如管辖地点正确与否） 3. 外国法律和地方性法规、习惯 4. 证据性事实	5. 已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实 6. 已为仲裁机构生效裁决所确认的事实 7. 已为有效公证文书所证明的事实 8. 当事人在诉讼中自认的事实 第 2 项至第 4 项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第 5 项至第 7 项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外

【考点4】简易程序（★★★）

一、简易程序特点

项目	内容
方式	可以口头起诉
程序	可以当即审理，也可以另定日期审理
传唤	可以用简便方式随时传唤当事人、证人
组织	实行独任制
开庭	无须事前通知、公告，无须遵循普通程序规定的审理阶段
审限	应当在立案之日起 3 个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长 1 个月

二、简易程序的适用范围与特殊规定

（一）适用范围

1. 适用简易程序的案件：基层法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系 明确、争议不大的简单的民事案件。

2. 约定适用：基层人民法院和其派出的法庭审理法定适用简易程序以外的民事案 件，当事人双方也可以约定适用简易程序。

【注】 双方约定适用简易程序应当在开庭前提出，口头提出的应记入笔录，由双方当事人签字或盖章。

3. 不适用简易程序的案件：

（1）起诉时被告下落不明的；

（2）发回重审的；

（3）当事人一方人数众多的；

（4）适用审判监督程序的；

（5）涉及国家利益、社会公共利益的；

（6）第三人起诉请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书的；

（7）其他不宜适用简易程序的案件。

（二）简易程序转为普通程序

1. 法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。案件转为普通程序审理的，审理期限自法院立案之日计算。但是， 已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理。

2. 在简易程序进行中，允许当事人对适用简易程序提出异议。当事人一方或者双方就适用简易程序提出异议后，法院应当进行审查。异议成立的，应当将案件转入普 通程序审理，并将合议庭的组成人员及相关事项以书面形式通知双方当事人；异议不 成立的，口头告知双方当事人，并将上述内容记入笔录。

（三）其他特殊规定

1. 基层法院和它派出的法庭审理简单的民事案件，可以用简便方式传唤当事人和证人、送达诉讼文书、审理案件；但应保障当事人陈述意见的权利。

2. 适用简易程序审理的民事案件，应当一次开庭审结，但法院认为确有必要再次开庭的除外。

3. 法院在制作裁判文书时对认定事实或者判决理由部分可以适当简化的情形：

（1）当事人达成调解协议并需要制作民事调解书的；

（2）一方当事人在诉讼过程中明确表示承认对方全部诉讼请求或者部分诉讼请 求的；

（3）当事人对案件事实没有争议或者争议不大的；

（4）涉及个人隐私或者商业秘密的案件，当事人一方要求简化裁判文书中的相 关内容，法院认为理由正当的；

（5）当事人双方一致同意简化裁判文书的。

第十八章 刑法

【考点1】追诉时效(★★★)

一、追诉时效的期限

法定最高刑 X	追诉时效	起算点
X<5 年	5 年	1. 没有连续状态的犯罪 （犯罪之日起算） 2. 有连续状态的犯罪（从犯罪行为终了之日起算）
5 年≤ X<10 年	10 年	
X ≥ 10 年	15 年	
无期徒刑、死刑	20 年	
	20 年后认为必须追诉，报请最高人民检察院核准	

二、追诉期限的计算

（一）不受追诉期限的限制

1. 在检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或在法院受理案件以后，逃避侦查或审判的。

2. 被害人在追诉期限内提出控告，法院、检察院、公安机关应当立案而不予立案的。

（二）追诉时效中断

犯罪分子在实施犯罪行为后，在追诉时效期限内又犯罪的，前罪的追诉时效就此 中断，并从后罪成立之日起重新计算。

【考点2】累犯、自首、立功(★★★)

一、累犯

1. 一般累犯，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后， 在 5 年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪、缓刑假释期满之日起 5 年内和不满 18 周岁的人犯罪的除外。

2. 特别累犯，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪，都以累犯论处。

	一般累犯	特别累犯
主观方面	前罪和后罪都必须是故意犯罪	前罪和后罪都必须是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪

后罪发生时间	后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免后的 5 年之内	后罪必须发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后（任何时间）

二、自首

概念	犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为 【注】自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪嫌疑人尚未受到调查谈话、讯问或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向公安机关、人民检察院或者人民法院投案的行为（2025 年调整）
视为自动投案	1. 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案【注】犯罪分子向所在单位等办案机关以外的单位、组织或者有关负责 人员投案的，应当视为自动投案（2025 年新增） 2. 犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案， 或者先以信电投案 3. 罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘 问、教育后，主动交代自己的罪行 4. 犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案 5. 经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获 6. 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案 7. 公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑 人送去投案 8. 犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法 机关询问时交代自己罪行 9. 明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实 10. 在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己 罪行 11. 因特定违法行为被采取行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、 司

	法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为 12. 其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形
自首的 认定	1. 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首 2. 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首 3. 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首 4. 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首（2025 年新增） 5. 单位犯罪案件中，单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代单位犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实的，应当认定为单位自首（2025 年新增） 6. 单位自首的，直接负责的主管人员和直接责任人员未自动投案，但如实交代自己知道的犯罪事实的，可以视为自首；拒不交代自己知道的犯 罪事实或者逃避法律追究的，不应当认定为自首（2025 年新增） 7. 单位没有自首，直接责任人员自动投案并如实交代自己知道的犯罪事 实

	的对该直接责任人员应当认定为自首（2025 年新增）
以自首论	1. 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同罪行的，以自首论（2025 年调整） 2. 没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论： （1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的 （2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的（2025 年新增） 3. 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯如实供述的罪行与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚

量刑规定	1. 对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的， 可以免除处罚 【注】对于具有自首情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情 节和对于社会的危害程度，结合自动投案的动机、阶段、客观环境，交 代犯罪事实的完整性、稳定性以及悔罪表现等具体情节，依法决定是否 从轻、减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度（2025 年新增） 2. 犯罪嫌疑人虽不具有规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可 以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以 减轻处罚 3. 共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以 酌情子以从轻处罚

三、立功

概念	犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要案件线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，有一般立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚
一般立功（ 可以从轻、减轻处罚）	1. 到案后检举、揭发他人，包括揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实 2. 提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实 3. 阻止他人犯罪活动 4. 协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人 5. 具有其他有利于国家和社会的突出表现
重大立功（ 可以减轻、免除处罚）	1. 有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实 2. 提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实 3. 阻止他人重大犯罪活动 4. 协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人 5. 对国家和社会有其他重大贡献等表现

立功的认定（2025年新增）	1. 犯罪分子揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件重要线索的，必须经查证属实才能认定为立功 2. 犯罪分子揭发他人犯罪行为时没有指明具体犯罪事实的；揭发的犯罪事实与查实的犯罪事实不具有关联性的；提供的线索或者协助行为对于 其他案件的侦破或者其他犯罪嫌疑人的抓捕不具有实际作用的，不能认 定为立功表现 3. 据以立功的线索、材料来源有下列情形之一的，不能认定为立功： （1）本人通过非法手段或者非法途径获取的 （2）本人因原担任的查禁犯罪等职务获取的 （3）他人违反监管规定向犯罪分子提供的 （4）负有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员或者其他国家工作人员利用职务便利提供的 4. 犯罪分子检举、揭发的他人犯罪，提供侦破其他案件的重要线索，阻止他人的犯罪活动，或者协助司法机关抓捕的其他犯罪嫌疑人，犯罪嫌 疑人、被告人依法可能被判处无期徒刑以上刑罚的，应当认定为有重大 立功表现。其中，可能被判处无期徒刑以上刑罚，是指根据犯罪行为的事实、情节可能判处无期徒刑以上刑罚。案件已经判决的，以实际判处 的刑罚为准。但是，根据犯罪行为的事实情节应当判处无期徒刑以上刑罚， 因被判刑人有法定情节经依法从轻、减轻处罚后判处有期徒刑的，应当认定为重大立功
立功的 处理	1. 有一般立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的， 可以减轻或者免除处罚 2. 对于具有立功情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合立功表现所起作用的大小、所破获案件的罪行轻重、所抓获犯罪嫌疑人可能判处的法定刑以及立功的时机等具体情节，依法决定是否从轻减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度（2025 年新增）

【考点3】缓刑(★★★)

一、缓刑的适用对象和条件

对象	条件	缓刑适用
被判处拘役或者 3 年以下有期徒刑	1. 犯罪情节较轻 2. 有悔罪表现	可以宣告缓刑
拘役或者 3 年以下有期徒刑＋不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁	3. 没有再犯罪的危险 4. 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响	应当宣告缓刑
【注】被判处拘役或者 3 年以下有期徒刑，是指宣告刑，而不是法定刑		

二、缓刑的适用

不适用缓刑的情形	对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑
应当撤销缓刑的情形	1. 在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的（新罪或漏罪） 2. 在缓刑考验期限内违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监管规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的

三、缓刑考验期限及禁止令的期限

刑种	法定刑期	缓刑考验期	禁止令的期限
拘役	1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚不超过 1 年	原判刑期以上 1 年以下，但是不能少于 2 个月	1. ≤缓刑考验期限，但不得短于 2 个月 2. 执行期限，从缓
有期徒刑	3 年以下	原判刑期以上 5 年以下，但是不能少于 1 年	

1. 考验期限≥原判刑期 2. 考验期限，从判决确定之日起计算 3. 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍需执行	刑执行之日起计算 3. 被依法减刑时，禁止令的期限可以相应缩短

【考点4】减刑（★★★）

一、减刑的对象和条件

对象	管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子	
适用	可以减刑	认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改、立功表现
	应当减刑	有重大立功表现

二、减刑起始时间

刑罚种类	原判刑期 / 法定情形	减刑起始时间	
		一般	原国家工作人员犯贪 污受贿罪
有期徒刑	不满 5 年	执行 1 年以上	2 年以上（判处不满 10 年）
	5 年以上不满 10 年有期徒刑	执行 1 年 6 个月以上	
	10 年以上有期徒刑	执行 2 年以上	3 年以上
无期徒刑	一般	执行 2 年以上	4 年以上

注意	有重大立功表现的，可以不受减刑起始时间的限制	
死刑 缓期执行	没有故意犯罪，2 年期满以后	减为无期徒刑
	确有重大立功表现，2 年期满以后	减为 25 年有期徒刑
死缓 减为无期	一般	（无期）执行 3 年以上
	原国家人员＋犯贪污受贿罪	（无期）执行 4 年以上
	数罪并罚的死缓减为无期	（无期）执行 3 年以上

	被限制减刑的死缓减为无期	（无期）执行 5 年以上

三、减刑间隔时间（指前一次减刑裁定送达之日至本次减刑报请之日的期间）

刑罚种类	原判刑期	减刑的间隔时间	原国家人员（贪污受贿）
有期徒刑	不满 10 年	间隔不得少于 1 年	1 年 6 个月以上
	10 年以上	间隔不得少于 1 年 6 个月	2 年以上
无期徒刑	间隔时间不得少于 2 年		2 年以上
死缓→无期徒刑→有期→有期		间隔不得少于 2 年	2 年以上
数罪并罚 + 死缓→无期徒刑→有期		间隔 2 年以上	
被限制减刑的死缓→无期→有期→ 有期		不得少于 2 年	

四、减刑后的实际执行刑期

判处管制、拘役、有期徒刑的	不能少于原判刑期的 1/2，从判决执行之日起计算
判处无期徒刑的	不能少于 13 年，自无期徒刑判决确定之日起计算
被判处死刑缓期执行的	不得少于 15 年，死刑缓期执行期间不包括在内（至少 17 年）
累犯/ 因故意杀人、强奸、抢劫、 绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪 + 判处死缓 + 限制减刑	1. 缓刑执行期满后减为无期徒刑的，不能少于 25 年 2. 缓刑执行期满后直接减为 25 年有期徒刑的，不 得少于 20 年

五、减刑的要求

有期、无期徒刑执行 期间又故意犯罪	新罪被判处有期徒刑	新罪判决确定之日起 3 年内不予减刑
	新罪被判无期徒刑	新罪判决确定之日起 4 年内不予减刑
死缓执行期间又故意 犯罪	未被执行死刑	1. 死刑缓期执行的期间重新计算 2. 减为无期徒刑后，5 年内不予减刑

死缓执行期间，不服从监管、抗拒改造，尚未构成犯罪的	在减为无期徒刑后再减刑时应当适当从严
对被判处终身监禁的	在死缓减为无期徒刑的裁定中，应当明确终身监禁，不得再减刑或者假释

【考点5】假释（★★★）

含义	对判处有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期后，确有悔改表现，不致再危害社会，附条件地予以提前释放的刑罚执行制度。
对象	被判处有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子
条件	1. 有期徒刑：必须执行原判刑期 1/2 以上 2. 无期徒刑的：实际执行 13 年以上 3. 认真遵守监规，确有悔改表现、没有再犯罪的危险 4. 如有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制
假释的刑期	1. 被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期 1/2 以上判决生效前先行羁押的，羁押 1 日折抵刑期 1 日 2. 被判处无期徒刑的，实际执行 13 年以上，先行羁押的时间不予折抵 3. 死缓→无期 / 有期的，实际执行 15 年以上，方可假释
假释的限制	1. 累犯 2. 因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释 3. 对于生效裁判中有财产性判项，罪犯确有履行能力而不履行或者不全部履行的，不予假释 4. 被撤销假释的罪犯，一般不得再假释
减刑与假释的适用关系	1. 罪犯既符合法定减刑条件，又符合法定假释条件的，可以优先适用假释 2. 年满 80 周岁、身患疾病或者生活难以自理、没有再犯罪危险的罪犯，既符合减刑条件，又符合假释条件的，优先适用假释
假释的考	有期徒刑：没有执行完毕的刑期；无期徒刑：10 年

验期	
假释的 撤销	1. 被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照规定实行数罪并罚 2. 在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照规定实行数罪并罚。（漏罪） 3. 被假释的犯罪分子，在假释考验期限内， 有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚

职业禁止	因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为 3-5 年

【考点6】逃税罪（★★★）

一、逃税罪的犯罪构成

1. 客体：国家税收征收管理制度。

2. 客观方面：表现为采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，不缴或 者少缴税款行为。

项目	内容
纳税人欺骗、隐瞒手段的情形	1. 伪造、变造、转移、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证或者其他涉税资 料的 2. 以签订“阴阳合同”等形式隐匿或者以他人名义分解收入、财产的 3. 虚列支出、虚抵进项税额或者虚报专项附加扣除的 4. 提供虚假材料，骗取税收优惠的 5. 编造虚假计税依据的 6. 为不缴、少缴税款而采取的其他欺骗、隐瞒手段

“不申报”的情形	1. 依法在登记机关办理设立登记的纳税人，发生应税行为而不申报纳税的 2. 依法不需要在登记机关办理设立登记或者未依法办理设立登记的纳税人，发生应税行为，经税务机关依法通知其申报而不申报纳税的 3. 其他明知应当依法申报纳税而不申报纳税的
应予立案追诉的情形	1. 纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款， 数额在 10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10% 以上，经税务机关依法 下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的 2. 纳税人 5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 2 次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在 10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10% 以上的 3. 扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 10 万元以上的

3. 犯罪主体

逃税罪的主体为特殊主体，既可以是个人，也可以是单位；包括纳税人和扣缴义 务人。

【注】 不负有纳税义务和扣缴义务的单位和个人，不能独立构成本罪主体，但可 成为本罪的共犯。

4. 主观方面：直接故意。

二、逃税罪的处罚

1. 对多次实施逃税行为，未经处理的，按照“累计数额”计算（连续犯）。

【注】“未经处理”，包括未经行政处理和刑事处理。

2. 纳税人有刑法规定的逃避缴纳税款行为，在公安机关立案前，经税务机关依法下达追缴通知后，在规定的期限或者批准延缓、分期缴纳的期限内足额补缴应纳税款， 缴纳滞纳金，并全部履行税务机关作出的行政处罚决定的，不予追究刑事责任。

但是，5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 2 次以上行政处罚的除外。

纳税人有逃避缴纳税款行为，税务机关没有依法下达追缴通知的，依法不予追究刑事责任。

【注】（1）“逃避缴纳税款数额”，是指在确定的纳税期间，不缴或者少缴税务机关负责征收的各税种税款的总额。

（2）“应纳税额”，是指应税行为发生年度内依照税收法律、行政法规规定应当缴纳的税额，不包括海关代征的增值税、关税等及纳税人依法预缴的税额。

（3）“逃避缴纳税款数额占应纳税额的百分比”，是指行为人在一个纳税年度中的各税种逃税总额与该纳税年度应纳税总额的比例；不按纳税年度确定纳税期的，按照最后一次逃税行为发生之日前一年中各税种逃税总额与该年应纳税总额的比例确定。纳税义务存续期间不足一个纳税年度的，按照各税种逃税总额与实际发生纳税义 务期间应纳税总额的比例确定。

逃税行为跨越若干个纳税年度，只要其中一个纳税年度的逃税数额及百分比达到规定的标准（ 10 万元以上、10% 以上），即构成逃税罪。各纳税年度的逃税数额应 当累计计算，逃税额占应纳税额百分比应当按照各逃税年度百分比的最高值确定。

【考点7】骗取出口退税罪(★★★)

主体	1. 既可以是纳税人，也可以是非纳税人（一般主体） 2. 既可以是个人，也可以是单位（不限于是否有进出口经营权）
客体	复杂客体 = 国家出口退税管理制度十公共财产所有权
主观方面	直接故意，且具有骗取国家出口退税款的目的
客观方面	利用国家出口退税政策，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在 10 万元以上的行为

假报出口或者其他欺骗手段	1. 使用虚开、非法购买或者以其他非法手段取得的增值税专用发票 或者其他可以用于出口退税的发票申报出口退税的 2. 将未负税或者免税的出口业务申报为已税的出口业务的 3. 冒用他人出口业务申报出口退税的 4. 虽有出口，但虚构应退税出口业务的品名、数量、单价等要素， 以虚增出口退税额申报出口退税的 5. 伪造、签订虚假的销售合同，或者以伪造、变造等非法手段取得 出口报关单、运输单据等出口业务相关单据、凭证，虚构出口事实 申报出口退税的 6. 在货物出口后，又转入境内或者将境外同种货物转入境内循环进 出口并申报出口退税的 7. 虚报出口产品的功能、用途等，将不享受退税政策的产品申报为 退税产品的 8. 以其他欺骗手段骗取出口退税款的
【注】 1. 骗超了才是本罪 骗取所缴税款的，按逃税罪处罚；骗取税款超过所缴纳的税款部分，以骗取出口退 税罪论处。例如：缴纳税款 10 万元，虚报出口骗取 15 万元，则对其中的 10 万部分 按逃税罪处罚；5 万元的部分按照骗取出口退税罪论处 2. 实施骗取出口退税罪，同时构成虚开增值税专用发票等其他犯罪的，根据牵连犯 从一重罪处断原则，按处罚较重的罪名定罪处罚	

【考点8】涉税职务犯罪的主体(★★★)

徇私舞弊不征、少征税款罪	税务机关工作人员
徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪	税务机关工作人员
徇私舞弊不移交刑事案件罪	行政执法人员
违法提供出口退税凭证罪	海关、外汇管理等国家机关工作人员

第十九章 刑事诉讼法

【考点1】刑事诉讼当事人与参与人(★★★)

一、刑事诉讼的当事人

（一）刑事诉讼中的被害人与自诉人

范围	被害人、 自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼的原告人和被告 人 【注】 与案件事实和诉讼结果有切身利害关系，在诉讼中处于控告或者 被控告地位的诉讼参与人
被害人	合法权益遭受犯罪行为侵害的人
自诉人	以个人名义直接向人民法院提起诉讼，要求追究被告人刑事责任的人（自 诉案件的一方当事人，具有独立的诉讼地位，在诉讼中执行控诉职能） 【注】 通常情况下，自诉人是该案件的被害人，或者是被害人的法定代理 人
犯罪嫌疑人、被告人	1. 犯罪嫌疑人：在公诉案件中，因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人，在人 民检察院向人民法院提起公诉以前，是犯罪嫌疑人 2. 被告人：在公诉案件中，因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人，在人民检 察院向人民法院提起公诉以后，是被告人 【注】 涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人在不同的刑事诉讼程序中有两种不 同的称谓

（二）其他刑事诉讼参与人

法定代理人	被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表 【注】 法定代理人参加诉讼时，享有申请回避、提出上诉等独立的诉认权利
诉讼代理人	公诉案件的被害人及其法定代理人或者近亲属、自诉案件的自诉人及其 法定代人委托代为参加诉讼的人和附带民事诉讼的当事人及其法定代理 人委托代为参加诉讼的人 【注】 “近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹（刑诉 法意义上的近亲属与民法不是同一概念）
辩护人	依法接受委托或指定，参加诉讼并为犯罪嫌疑人或被告人进行辩护的诉 讼参

	与人
证人	当事人以外的、就自己知道的案件情况向司法机关作证的人 【注】 证人只能是自然人；生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别 是非不能正确表达的人，不能作证人

鉴定人	受司法机关的指派或者聘请，运用专门知识和技能，对案件中的专门性 问题进行鉴别判断的诉讼参与人
翻译人员	接受司法机关委托，在刑事诉讼中进行语言、文字翻译的诉讼参与人

【提示】刑事诉讼参与人不包括侦查人员、检察人员和审判人员（审判人员包括 审判员和人民陪审员）。

【考点2】管辖制度（★★★）

级别管辖	1. 我国实行两审终审制 2. 基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依法由上级人民法院管 辖的除外 3. 中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：危害国家安全、恐怖活动案 件；可能判处无期徒刑、死刑的刑事案件；适用违法所得没收程序的案 件；适用缺席审判程序审理的案件 4. 高级人民法院管辖的第一审刑事案件，是全省（自治区、直辖市）性 的重大刑事案件 5. 最高人民法院管辖的第一审刑事案件，是全国性的重大刑事案件 6. 上级人民法院在必要的时候，可以审判下级人民法院管辖的第一审刑 事案件；下级人民法院认为案情重大、复杂，需要由上级人民法院审判 的第一审刑事案件，可以请求移送上一级人民法院审判

地域管辖	1. 刑事案件由犯罪行为地的人民法院管辖，如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖 2. 对罪犯在服刑期间发现漏罪及又犯新罪的特殊情况，其管辖原则： （1）发现正在服刑的罪犯在判决宣告前还有其他犯罪没有受到审判的，由原审人民法院管辖，如果罪犯服刑地或者新发现罪的主要犯罪地人民法院管辖更为适宜的，由服刑地的人民法院管辖 （2）正在服刑的罪犯在服刑期间又犯罪的，由服刑地人民法院管辖 （3）正在服刑的罪犯在逃脱期间的犯罪，如果是在犯罪地捕获并发现的，由犯罪地人民法院管辖；如果是被缉捕押解回监狱后发现的，由罪犯服刑地的人民法院管辖
专门管辖	专门管辖是指普通人民法院与专门人民法院之间、各专门人民法院之间审判第一审刑事案件的权限划分，如军事法院、海事法院、知识产权法 院、金融法院等。其中，只有军事法院具有刑事案件审判权
指定管辖	指管辖不明、管辖不宜、规避管辖等。管辖权发生争议，由争议双方法院协商；协商不成的，分别层报共同上级法院指定管辖
并案管辖	1. 将原本应由不同机关管辖的数个案件，合并由同一个机关管辖 2. 一人犯数罪、共同犯罪和其他需要并案审理的案件，其中一人或者一罪属于上级人民法院管辖的，全案由上级人民法院管辖

【考点3】强制措施（★★★）

一、拘传

概念	公、检、法机关对未被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人、被告人强制其到案接受讯问的一种强制措施
批准机关	必须经公、检、法、机关负责人审批
执行机关	公检法机关，应当有 2 人以上的执行人员
适用条件	对经依法传唤拒不到庭的被告人，或者根据案情有必要拘传的被告人，可以拘传

次数与时间	1. 次数法律没有明确规定，但不得以连续拘传的方式变相拘禁犯罪嫌疑人 2. 持续时间不得超过 12 小时；案情特别重大、复杂， 需要采取拘留、逮捕措施的，持续的时间不得超过 24 小时
地点	1. 应在犯罪嫌疑人被告人所在的市、县的地点进行 2. 如果犯罪嫌疑人的工作单位、户籍地与居住地不在同一市、县，拘传应当在犯罪嫌疑人的工作单位所在地的市、县进行 3. 特殊情况下，也可以在犯罪嫌疑人户籍地或者居住地所在的市、县内进行
处理	1.公安机关、人民检察院和人民法院将犯罪嫌疑人、被告人拘传到案后，应当立即讯问 2. 讯问结束后，应根据案件的情况作出不同的处理： （1）认为依法应当限制或剥夺其人身自由的可以采用其他相应的强制措施 （2）在拘传期间决定不采取其他强制措施的，拘传期限届满，应当结束拘传 3. 需要对被拘传的犯罪嫌疑人变更强制措施的，应当在拘传期限内办理变更手续

二、取保候审

条件	1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的 2. 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的 3. 患有严重疾病、生活不能自理， 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的 4. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的
不得适用取保候审的情形	1. 公安机关：对累犯，犯罪集团的主犯、以自伤、 自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人、严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的嫌疑人不得取保候审 2. 检察院：对于严重危害社会治安的嫌疑人、以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人不得取保候审

申请	1. 被羁押、监视居住以及被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人，有权向公安机关、人民检察院、人民法院 申请取保候审 2. 公安机关、人民检察院、人民法院接到取保候审申请书后，应当在 3 日内作出是否同意的答复
取保候审的保证	1. 保证人或交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人，不得同时使用保证人和保证金 2. 取保的方式 符合取保受审条件，责令提供 1 至 2 名保证人的情形： （1）无力交纳保证金的 （2）系未成年人或者已满 75 周岁的人 （3）不宜收取保证金的 3. 保证人履行以下义务 （1）监督被保证人遵守相关规定 （2）发现被保证人可能发生或者已经发生违反相关规定的行为的， 应当及时向执行机关报告（对保证人是否履行了义务，由公安机关认定） 4. 采取保证金保证方式的，提供保证金的人一次性将保证金存入公安机关指定银行的专门账户，取保候审结束时，凭解除取保候审通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金
取保候审保证方式的变更	1. 保证人保证方式 保证人在取保候审期间不愿继续保证或丧失保证条件的，检察院、法 院应当在收到保证人申请或发现其丧失保证条件后 3 日以内，责令犯 罪嫌疑人重新提出保证人或者交纳保证金，并将变更情况通知公安机 关 2. 保证金保证方式 被取保候审人拒绝交纳保证金或交纳保证金不足决定数额时，检察院 应当作出变更取保候审措施、变更保证方式或者变更保证金数额的决 定，并将

	变更情况通知公安机关
执行	1. 犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定 （1）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县 （2）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在 24 小时以内向执行 机关报告 （3）在传讯的时候及时到案 （4）不得以任何形式干扰证人作证 （5）不得毁灭、伪造证据或者串供 2. 公检法可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人 遵守以下一项或者多项规定： （1）不得进入特定的场所 （2）不得与特定的人员会见或者通信 （3）不得从事特定的活动 （4）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存

期限与解除	1. 期限：最长不得超过 12 个月 2. 解除：对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审期限届满的，应 当及时解除或者撤销取保候审 3. 在取保候审期间，不得中断对案件的侦查、审查起诉和审理

三、监视居住

条件	1. 患有严重疾病、生活不能自理的 2. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女 3. 系生活不能自理的人的唯一扶养人 4. 因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为 适宜的 5. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的 6. 对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也 不交纳保证金的，可以监视居住
执行场所和方法	1. 监视居住由公安机关执行 2. 执行场所 （1）监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行 （2）无固定住处的，可以在指定的居所执行 （3）对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级检察院或者公安机关批准，也可以在指定的居所执行 （4）不得在羁押场所、专门的办案场所执行 3. 执行方法 电子监控、不定期检查等。侦查期间，还可通信监控
被监视居住人的义务	1. 未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所（如有正当理由，执行机关应征得决定机关的同意后批准） 2. 未经执行机关批准不得会见他人或者通信 3. 在传讯的时候及时到案 4. 不得以任何形式干扰证人作证 5. 不得毁灭、伪造证据或者串供 6. 将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存
通知与监督	1. 指定居所监视居住，除无法通知的外，人民检察院、人民法院应当在执行监视居住后 24 小时以内，将监视居住的原因和处所通知被监视居住人的家属 2. 人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督

期限	1. 最长不超过 6 个月 2. 在监视居住期间，不得中断对案件的侦查、审查起诉和审理

四、拘留

情形	1. 公安机关实施的拘留 （1）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的 （2）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的 （3）在身边或者在住处发现有犯罪证据的 （4）犯罪后企图自杀、逃跑或在逃的 （5）有毁灭、伪造证据或者串供可能的 （6）不讲真实姓名、住址、身份不明的 （7）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的 2. 检察机关实施的拘留 人民检察院对犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃和有毁灭、伪造证据或者串供可能情形之一的犯罪嫌疑人，可以决定拘留
通知	1. 对于现行犯或者重大嫌疑分子的拘留，或者根据人民检察院决定做出的拘留，公安机关均应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过 24 小时 2. 除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查 的情形以外，公安、检察院应当在拘留后 24 小时以内，通知被拘留人的家属 3. 检察院在24 小时以内无法通知被拘留人家属的，应当将原因写明附卷。
讯问	1. 公安机关、检察机关对于被拘留的人，应当在拘留后的 24 小时内进行讯问 2. 检察院直接受理侦查的案件，拘留犯罪嫌疑人的羁押期限为 14 日，特殊情况下可以延长 1-3 日
执行机关	由公安机关执行。公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证

五、逮捕

概念	公安司法机关依法对犯罪嫌疑人、被告人实行羁押，暂时剥夺人身自由的一 种强制措施
决定	逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定
执行	公安机关（公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证）
逮捕情形	对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人， 采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当子以逮捕： 1. 可能实施新的犯罪的 2. 有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的 3. 可能毁灭伪造证据、干扰证人作证或者串供的 4. 可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的 5. 企图自杀或者逃跑的
	对有证据证明有犯罪事实，可能判处 10 年有期徒刑以上刑罚的，或者有证 据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的， 应当子以逮捕
	被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定， 情节严重的，可以予以逮捕

提请逮捕	1. 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的 3 日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长 1-4 日 2. 对于流帘作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时 间可以延长至 30 日	
审查	讯问	人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人；有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人 1. 对是否符合速捕条件有疑问的 2. 犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的 3. 侦查活动可能有重大违法行为的
	听取意见	人民检察院审查批准速捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取护律师 的意见

		辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见
决定期限	人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的 7 日以内，作出批准逮 捕或者不批准逮捕的决定	
羁押	逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押	
讯问	人民法院、人民检察院对于各自决定逮捕的人，公安机关对于经人民检察院 批准逮捕的人，都应当在逮捕后的 24 小时以内进行讯问	
通知	除无法通知的以外，应当在逮捕后 24 小时以内，通知被逮捕人的家属。人 民法院逮捕被告人后，应当将逮捕的原因和羁押的处所，在 24 小时以内通 知其家属	

【考点4】刑事诉讼程序（★★★）

一、立案的条件

公诉案件	1. 有犯罪事实 有犯罪事实，是指已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构 成了犯罪。其包含两方面内容：一是要立案追究的，必须是依照刑法规定构 成犯罪的行为。二是要有一定的事实材料证明犯罪事实确已发生，包括犯罪 行为已经实施、正在实施和预备犯罪 2. 需要追究刑事责任 需要追究刑事责任，是指依法应当追究犯罪行为人的刑事责任。即犯罪嫌疑 人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚
自诉案件	由于自诉案件不经过侦查， 自诉人直接向人民法院起诉，符合立案条件的， 人民法院应当受理并直接进入审判程序，因此自诉案件除了应当具备公诉案 件的两个立案条件，还应具备以下条件： 1. 属于《刑诉法》第 210 条规定的自诉案件的范围和《司法解释》第 1 条的规定 2. 属于该人民法院管辖 3. 被害人告诉的 4. 有明确的被告人、具体的诉讼请求和证明被告人犯罪事实的证据

二、侦查

（一）侦查措施

1. 讯问犯罪嫌疑人

人员要求	必须由检察院侦查人员、公安机关侦查人员进行，人员不得少于 2 人
讯问地点	1. 被羁押的：应当在看守所内进行讯问 2. 不需要逮捕、拘留的：可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内指定地点或住处 3. 犯罪嫌疑人工作单位与居住地不在同一市、县的，传唤应当在犯罪嫌疑人工作单位所在的市、县内进行；特殊情况下，也可以在嫌疑人居住地所在的市、县内进行 4. 对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，并将传唤的原因和依据告知被传唤人。在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案时间、到案经过和传唤结束时间
讯问时间	传唤、拘传持续的时间不得超过 12 小时，案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过 24 小时。两次传唤间隔的时间一般不得少于 12 小时
讯问笔录	1. 讯问犯罪嫌疑人应当制作讯问笔录，并交犯罪嫌疑人核对或者向其宣读，经核对无误后逐页签名、盖章或者捺指印并附卷 2. 犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许，必要时，也可以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供述。犯罪嫌疑应当在亲笔供述的末页签名或者盖章，并捺指印，注明书写日期
录音录像	1. 讯问嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像 2. 对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像 3. 检察院办理直接受理侦查的案件，应当在每次讯问嫌疑人时，对讯问过程实行全程录音、录像，并在讯问笔录中注明

2. 勘验、检查

主体	侦查人员、检察人员	
对象	勘验的对象	是场所、物品和尸体
	检查的对象	活人的人身
检查勘验	1. 对于死因不明的尸体，公安机关、检察机关有权决定解剖，并且通 知死者家属到场 2. 为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进 行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。必要时， 可以强制检查 3. 勘验、检查的情况应当写成笔录，由参加勘验、检查的人和见证人 签名或者盖章	
侦查实验	批准主体：公安机关、检察机关负责人批准，可以进行侦查实验	

3. 搜查

搜查的对象和范围	1. 既可以是犯罪嫌疑人，也可以是其他可能隐藏罪犯或者犯罪证据 的人 2. 既可以对人身进行，也可以对被搜查人的住处、物品和其他有关 场所进行
搜查的程序	1. 必须向被搜查人或其家属出示搜查证 2. 检察人员执行搜查，人员不得少于 2 人 3. 侦查人员在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查 证也可以进行搜查。搜查结束后，24 小时以内补办有关手续

4. 技术侦查措施

手段	电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、录像、进行邮件检查 等秘密的专门技术手段

适用的案件	1. 危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重 大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件 2. 利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件 3. 追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人的 案件
期限	1. 对于复杂、疑难案件，期限届满，仍有必要继续采取技术侦查措 施的，应当在期限届满前 10 日内提出申请，经过原批准机关批准后， 技术侦察措施期限可以延长，但每次不得超过 3 个月

5. 通缉

有权机关	侦查机关有权发布通缉令，其他任何机关、团体、单位、组织和个 人都无权发布
被通缉的对象	必须是依法应当逮捕的犯罪嫌疑人在逃的，或者已被逮捕的犯罪嫌 疑人脱逃的
发布通缉令的范围	1. 检察机关决定通缉的，应当将通缉通知书和通缉对象的照片、身 份、特征、案情简况送达公安机关，由公安机关发布通缉令，追捕 归案 2. 为防止涉案人员外逃，需要在边防口岸采取边控措施的，检察机 关应制作边控对象通知书，商请公安机关办理边控手续 3. 应当逮捕的嫌疑人潜逃出境的，可层报最高检商请国际刑警组织 中国国家中心局，请求有关方面协助，或者通过其他法律规定的途 径进行追捕